

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

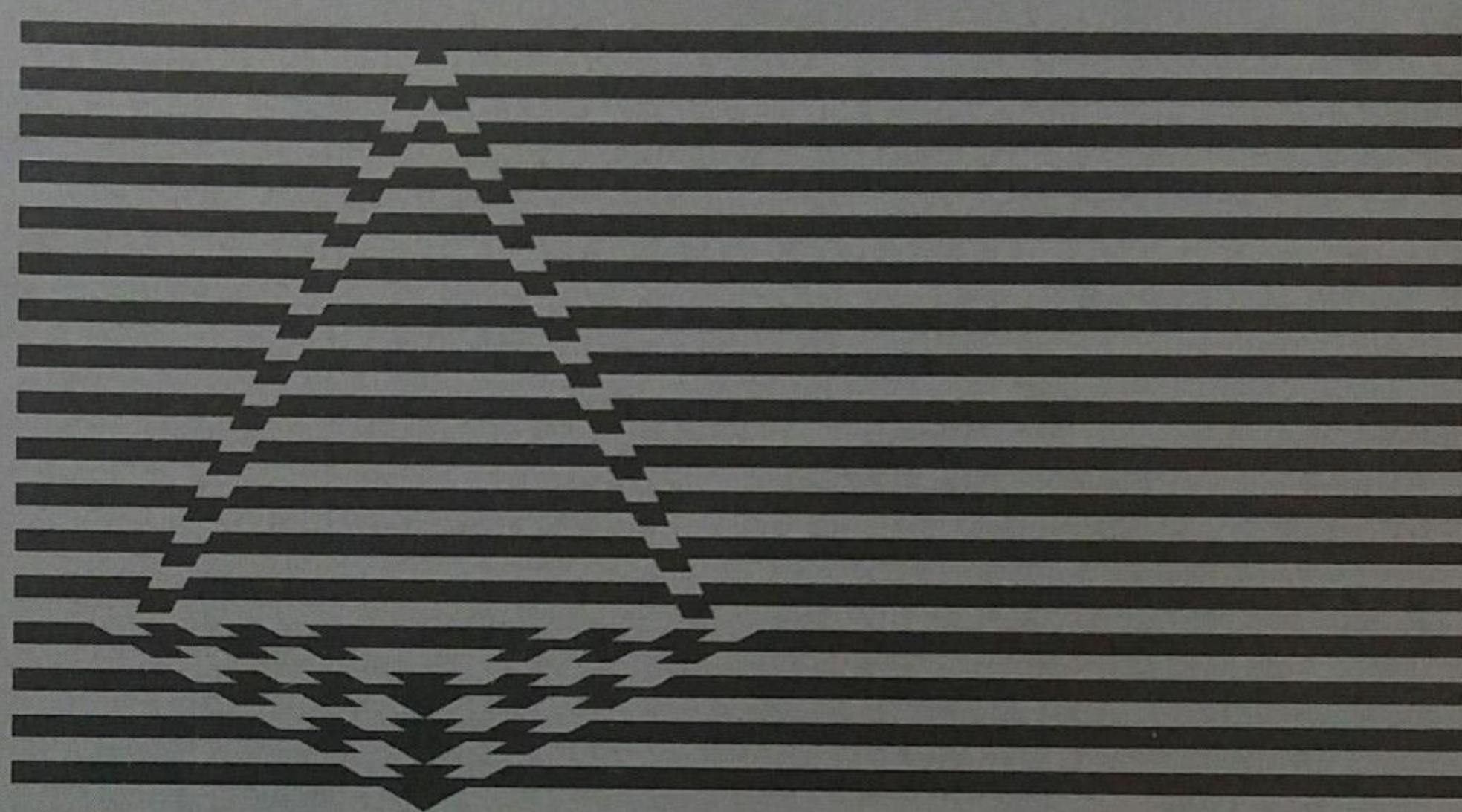
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 28 ฉบับที่ 2

กันยายน 2559 –
มีนาคม 2560



- ✧ แนะนำกฎหมายใหม่
- ✧ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา
- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา
- ✧ เฉลยข้อสอบบัณฑิตศึกษา

ฉบับนี้คือจบแล้ว

วิเคราะห์ข้อสอบ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อิงครัต ดลเจิม

คำถาม

นายเอ มาห้างสรรพสินค้าเพื่อจะซื้อโทรศัพท์มือถือ ระหว่างที่กำลังเลือกโทรศัพท์มือถือในร้านอยู่นั้น ก็สังเกตเห็นว่าพนักงานขายทุกคนในร้านกำลังดูแลลูกค้ารายอื่นอยู่ นายเอสบโอกาสจึงแอบขโมยโทรศัพท์มือถือไปจำนวน 5 เครื่อง แต่ขณะนั้นเจ้าของร้านได้เห็นเหตุการณ์ที่นายเอได้ขโมยโทรศัพท์มือถือจากกล่องวางจรปิดภายในร้าน เจ้าของร้านจึงรีบเดินออกมาหานายเอและพูดกับนายเอว่า ตนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และได้บอกกับนายเอว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ถ้านายเอไม่ทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ นายเอก็จะถูกดำเนินคดี จึงตกลงยอมตามที่ทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ตามที่เจ้าของร้านขายโทรศัพท์เสนอ

ให้นักศึกษาวินิจฉัยว่านิติกรรมการทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ ระหว่างนายเอกับเจ้าของร้านขายโทรศัพท์ มีผลอย่างไรตามกฎหมาย

หลักกฎหมาย

มาตรา 164 การแสดงเจตนาเพราะถูกข่มขู่เป็นโมฆียะ

การข่มขู่ที่จะทำให้การใดตกเป็นโมฆียะนั้น จะต้องเป็นการข่มขู่ที่จะให้เกิดภัยอันใกล้จะถึงและร้ายแรงถึงขนาดที่จะจูงใจให้ผู้ข่มขู่มีผลต้องกลัว ซึ่งถ้ามิได้มีการข่มขู่เช่นนั้น การนั้นก็คงมิได้กระทำขึ้น

มาตรา 165 การขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

การใดที่กระทำไปเพราะนับถือว่าจะเกรง ไม่ถือว่าการนั้นได้กระทำเพราะถูกข่มขู่

วินิจฉัย

จากกรณีตามปัญหา การที่เจ้าของร้านยื่นข้อเสนอกับนายเอให้นายเอทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์มีฉะนั้นจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ทำให้นายเอก็ถูกดำเนินคดีจึงยอมตกลงทำสัญญารับสภาพหนี้ตามที่เจ้าของร้านเสนอนั้น แสดงให้เห็นว่านายเอมิได้มีเจตนาจะทำนิติกรรมทำสัญญารับสภาพหนี้กับเจ้าของร้าน แต่เมื่อเจ้าของร้านข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ นายเอจึงตกลงยอมทำสัญญารับสภาพหนี้กับเจ้าของร้านตามที่เจ้าของร้านเสนอ เห็นว่าการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของนายเอ ดังกล่าวจึงเป็นการทำนิติกรรมที่เกิดจากการข่มขู่ แต่การทำนิติกรรมเพราะถูกข่มขู่ อันจะเป็นโมฆียะกรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 นั้น การข่มขู่ดังกล่าวต้องเป็นการข่มขู่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่หากเป็นการข่มขู่ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายหรือการข่มขู่ที่จะใช้สิทธิตามปกตินิยม ตามมาตรา 165 นั้น สามารถกระทำได้

เช่นนี้ การที่เจ้าของร้านจึงรีบเดินออกมาหานายเอและพูดกับนายเอว่า ตนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และได้บอกกับนายเอว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ถ้านายเอไม่ทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ นายเอกลัวจะถูกดำเนินคดี จึงตกลงยอมตามที่ทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ตามที่เจ้าของร้านขายโทรศัพท์เสนอ ดังกล่าว เป็นกรณีที่เจ้าของร้านฯ ช่มชู้ โดยมีหลักฐานว่าเจ้าของร้านผู้ช่มชู้มีมูลว่าจะฟ้องคดีอาญาแก่กับนายเอผู้ถูกช่มชู้ได้ เช่นนี้ถือว่าการช่มชู้โดยใช้สิทธิตามปกตินิยมซึ่งไม่ถือว่าการช่มชู้ ตาม ปพพ.165

สรุป การแสดงเจตนาซื้อโทรศัพท์ของนายเอกกับเจ้าของร้านไม่ตกเป็นโมฆียะ ตามข้อวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ถือเป็นการช่มชู้ ตามป.พ.พ. มาตรา 165 ที่บัญญัติว่า ในกรณีการชู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่ถือว่าการช่มชู้ ซึ่งการชู่จะใช้สิทธิตามปกตินิยม คือ การใช้สิทธิที่มีอยู่ช่มชู้และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีสิทธินั้นอยู่ในขณะช่มชู้ ไม่ถือว่าการชู่โดยใช้สิทธิตามปกตินิยม เช่น การที่เจ้าหนี้ชู่ลูกหนี้ว่า หากไม่ชำระหนี้จะฟ้องร้องต่อศาล หรือชู่ว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ถ้าไม่ทำสัญญารับสภาพหนี้ให้ผู้ชู่ โดยมีหลักฐานว่าผู้ชู่มีมูลที่จะฟ้องคดีอาญาแก่ผู้ถูกชู่ฐานลักทรัพย์ เช่นนี้ถือเป็นการชู่โดยใช้สิทธิตามปกตินิยม

จากโจทย์การที่เจ้าของร้านจึงรีบเดินออกมาหานายเอและพูดกับนายเอว่า ตนได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และได้บอกกับนายเอว่าจะดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ ถ้านายเอไม่ทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ นายเอกลัวจะถูกดำเนินคดี จึงตกลงยอมตามที่ทำสัญญารับสภาพหนี้ต่อร้านขายโทรศัพท์ตามที่เจ้าของร้านขายโทรศัพท์เสนอ ดังกล่าว เป็นกรณีที่เจ้าของร้านฯ ช่มชู้ โดยมีหลักฐานว่าเจ้าของร้านผู้ช่มชู้มีมูลว่าจะฟ้องคดีอาญาแก่กับนายเอผู้ถูกช่มชู้ได้ เช่นนี้ถือว่าการช่มชู้โดยใช้สิทธิตามปกตินิยมซึ่งไม่ถือว่าการช่มชู้ ตาม ปพพ.165

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดโดยวินิจฉัยว่าเมื่อนายเอแสดงเจตนาเพราะถูกช่มชู้แล้ว ย่อมเป็นโมฆียะทุกกรณีโดยนักศึกษาศึกษาเฉพาะหลักกฎหมายในป.พ.พ.มาตรา 164 ที่วางหลักไว้ว่าการแสดงเจตนาเพราะถูกช่มชู้เป็นโมฆียะแต่ไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ถือเป็นการช่มชู้ ตามป.พ.พ. มาตรา 165 ดังนั้น ในการศึกษาในลำดับต่อไปนักศึกษาควรจะต้องพิจารณาบริบทของหลักกฎหมายตลอดจนตรวจสอบว่าในหลักกฎหมายเรื่องนั้นมีข้อยกเว้นหรือไม่ หากมีข้อยกเว้นควรศึกษาว่ากฎหมายในเรื่องนั้นมีหลักการอย่างใดบ้างจึงจะทำให้ให้นักศึกษาทำความเข้าใจมาตรานั้น เรื่องนั้น ได้อย่างถูกต้อง



กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

อาจารย์ กฤติญดา เกิดลาภผล

คำถาม นายดียืมกระป๋องของนายดำเพื่อไปไถนาตกลงไว้ตลอดฤดูฝน ซึ่งเป็นการทำนา เมื่อสิ้นฤดูฝนแล้ว นายดีก็ยังไม่นำกระป๋องของนายดำไปคืน ต่อมานายดีไปเจอนายดำที่กลางตลาดนายดำจึงทวงถามนายดีให้นำกระป๋อง มาคืน เนื่องจากหมดฤดูทำนาหน้าฝนแล้ว แต่นายดีก็ยังไม่นำไปคืน คืนวันนั้นเกิดโรคระบาดในหมู่บ้าน โคและกระป๋อง ในหมู่บ้านตายหมด รวมทั้งกระป๋องของนายดำที่นายดียืมมาด้วย ดังนี้ นายดีจะต้องรับผิดชอบต่อนายดำหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 204 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือน ลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้อย่างไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว”

มาตรา 217 วรรคท้าย บัญญัติว่า “ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาท เลินเล่อในระหว่างเวลาที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะอุบัติเหตุ อันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลา กำหนด ก็คงจะต้องเกิดมีอยู่นั่นเอง”

วินิจฉัย

การที่นายดียืมกระป๋องของนายดำไปเพื่อไถนาโดยตกลงไว้ว่าจะยืมกระป๋องไว้ตลอดฤดูฝน เป็นการยืมที่ได้ กำหนดระยะเวลาชำระไว้ คือ ตลอดฤดูฝน แต่เป็นการยืมที่ไม่ได้กำหนดวันตามวันปฏิทินไว้ เจ้าหนี้จึงต้องให้คำเตือน การชำระหนี้แก่ลูกหนี้ก่อนจึงจะถือว่าลูกหนี้ผิดนัดเพราะเขาเตือน (ตามมาตรา 204 วรรค 1) จากข้อเท็จจริง นายดี ได้ไปเจอนายดำที่กลางตลาดและนายดำเจ้าหนี้ได้ทวงถามให้นายดีนำกระป๋องมาคืน ซึ่งได้หมดฤดูทำนาหน้าฝนแล้ว ถือได้ว่าเจ้าหนี้ได้ทวงถามลูกหนี้ให้ชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดแล้ว และเมื่อนายดีไม่ชำระหนี้ นายดีจึงได้ชื่อว่าผิดนัด เพราะเขาเตือนแล้ว ตาม ปพพ. มาตรา 204 วรรคหนึ่ง และนายดี ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดา ที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัดและทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลา กำหนด ก็ควรจะต้องเกิดมีอยู่นั่นเอง

ดังนั้น การที่นายดีไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา เมื่อเจ้าหนี้ได้เตือนแล้วจึงได้ชื่อว่าผิดนัด แต่ผิดอยู่ในคืน วันนั้น เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านโคและกระป๋องในหมู่บ้านตายหมด จึงเข้าข่ายยกเว้น ตามมาตรา 217 วรรคท้าย

เพราะแม้ว่านายดีจะได้คืนกระบือแก่นายดำแล้ว กระบือนั้นก็ตายอยู่ดี เนื่องจากเกิดโรคระบาดสัตว์ขึ้นในหมู่บ้านดังกล่าว และโคกระบือได้ตายหมดทั้งหมู่บ้าน ตาม ปพพ. มาตรา 217 วรรคท้าย

สรุป

ดังนั้น นายดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายดำ

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษาในเรื่อง **หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้** และผลของการที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่ตรวจพบคือ

1. ในส่วนของเนื้อหา

1.1 นักศึกษาบางส่วนวิเคราะห์ผิดว่ากรณีนี้ไม่ใช่หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ เพราะเข้าใจว่าหนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มีกรณีเดียวคือเป็นไปตามเวลาแห่งปฏิทิน นักศึกษาไม่ทราบว่า “หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้” จะแบ่งเป็น 2 กรณีคือ

(1) หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มีใช้ตามวันแห่งปฏิทิน ม.204 วรรคแรก “ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้ค่าเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว”

(2) หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน ม.204 วรรคสอง “ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่บอกกล่าว”

ซึ่งหนี้ในข้อนี้เป็นไปตามข้อ (1) หนี้ที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้มีใช้ตามวันแห่งปฏิทิน ตาม ม.204 วรรคแรก และเมื่อนักศึกษาวิเคราะห์ส่วนนี้ผิดไปวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามข้อ (2) แล้วจะวิเคราะห์ในส่วนคำถามต่อไปผิดไปด้วย

1.2 ในส่วนของผลของการผิดนัดลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดแต่การผิดนัดลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดระหว่างผิดนัดเพิ่มขึ้น หากเกิดความเสียหายเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ผิดนัดตาม ปพพ. มาตรา 217 นักศึกษาสับสนในส่วนของข้อยกเว้นตามมาตรา 217 ตอนท้าย ที่เป็นข้อยกเว้นว่าเมื่อปรากฏว่าการเสียหายนั้นแม้ลูกหนี้จะได้ปฏิบัติตามการชำระหนี้ตามกำหนดเวลาความเสียหายก็ยังคงเกิดอยู่นั่นเอง

2. ในส่วนของวิธีการตอบข้อสอบ

2.1 นักศึกษาไม่อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนการวินิจฉัยข้อเท็จจริงทำให้ปรับใช้หลักกฎหมายผิด นักศึกษาไม่สามารถนำหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ปรับแล้วนำมาเขียนเป็นคำตอบได้

นักศึกษาจึงต้องฝึกทักษะการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อกฎหมายในการตอบข้อสอบอัตนัย

2.2 นักศึกษาขาดทักษะในการใช้ภาษากฎหมายในการเขียนตอบข้อสอบ

นักศึกษาขาดการฝึกฝนในการเขียนตอบ การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมายนั้น นักศึกษาต้องเขียนตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนครบประเด็นเป็นขั้นเป็นตอนกะทัดรัด โดยใช้ภาษากฎหมาย ซึ่งจะต้องตอบถูกต้องตรงประเด็นครบถ้วน ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษากฎหมาย ชัดเจน กะทัดรัด ไม่ฟุ่มเฟือย

นักศึกษาจึงต้อง ฝึกทักษะการเขียนตอบข้อสอบให้มาก

2.3 นักศึกษาไม่ตอบในประเด็นที่โจทย์ถาม

การตอบไม่ตรงคำถาม ความผิดพลาดในการตอบลักษณะนี้ อาจจะทำให้ไม่ได้คะแนนเลย ทั้งที่นักศึกษาอุตส่าห์เขียนคำตอบมายาว

ทางแก้ คือให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำถาม เพื่อเน้นให้เห็นว่าคำถามถามอะไรกันแน่ เวลาเขียนคำตอบจะได้ไม่หลงประเด็น และเมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องอ่านทบทวน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ตอบคำถามโจทย์ข้อนี้ถูกต้องแล้ว

2.4 ลอกคำถามมาตอบ หรือบรรยายคำถามซ้ำ การลอกคำถามมาตอบย่อมไม่ได้คะแนนจากอาจารย์ผู้ตรวจ



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ผศ.วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

นายเหี่ยว เป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง นายเหี่ยวเป็นนักพนันตัวยง มีหนี้สินจำนวนมาก จึงต้องการเงินมาใช้หนี้ วันหนึ่งนายเหี่ยวเข้าไปทำความสะอาดในห้องพักของลูกค้ารายหนึ่งแล้วเห็นกระเป๋าสตางค์ของลูกค้าวางไว้ นายเหี่ยวจึงแอบหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาจากห้องพัก พอเปิดกระเป๋าสตางค์ดูก็เห็นรูปและชื่อในบัตรประชาชน นายเหี่ยวจึงจำได้ว่า คือนายเฉาเพื่อนสมัยเรียน ด้วยความสงสารเพื่อนจึงนำเอากระเป๋าสตางค์ของนายเฉาไปวางไว้ที่เดิม

นายเหี่ยวจะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 82 บัญญัติว่า ผู้ใดพยายามกระทำความผิด หากยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้น แต่ถ้าการที่ได้กระทำไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น ๆ

วินิจฉัย

หลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิดที่ผู้กระทำยับยั้งหรือกลับใจซึ่งจะทำให้ผู้กระทำได้รับการยกเว้นโทษนั้นต้องพิจารณาว่า ผู้กระทำต้องได้ลงมือกระทำความผิดแล้วตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องการพยายามกระทำความผิด กล่าวคือผู้กระทำจะต้องได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำและการยับยั้งหรือกลับใจนั้นได้กระทำในช่วงลงมือกระทำหรือช่วงพยายามกระทำความผิด และ ความผิดที่กระทำยังไม่สำเร็จตามเจตนาของผู้กระทำ หากเป็นกรณีที่มีความผิดนั้นสำเร็จตามที่ผู้กระทำเจตนาแล้ว ก็จะไม่มีการยกเว้นโทษจากการยับยั้งหรือกลับใจใดๆ ได้อีกผู้กระทำจึงไม่ได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา 82 ดังกล่าว

การที่นายเหี่ยวได้กระทำโดยเจตนาหยิบเอากระเป๋าสตางค์ของนายเฉาออกไปจากห้องพัก เป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดของการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว เพราะนายเหี่ยวได้ลงมือกระทำโดยเจตนาหยิบกระเป๋าสตางค์เคลื่อนที่ออกมาจากห้องพักแล้ว แม้ต่อมาเกิดความสงสารนายเฉาเพราะเป็นเพื่อนสมัยเรียนจึงนำกระเป๋าสตางค์ไปวางคืนไว้ที่เดิมก็ตาม เช่นนี้นายเหี่ยวก็ไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา 82 เนื่องจากความผิดฐานลักทรัพย์ได้สำเร็จไปแล้วตั้งแต่เมื่อตอนนายเหี่ยวหยิบกระเป๋าสตางค์ของนายเฉาเคลื่อนที่ออกมาแล้ว ดังนั้นการกระทำของนายเหี่ยวดังกล่าวจึงไม่ใช่การพยายามกระทำความผิดโดยยับยั้งหรือกลับใจซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นโทษตามมาตรา 82

สรุป

นายเหี่ยวต้องรับผิดชอบลัทธิพจน์โดยไม่ได้รับการยกเว้นโทษตามที่ได้อินิจฉัยแล้วข้างต้น

วิเคราะห์

จากการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยครั้งนี้ พบว่านักศึกษาตอบข้อนี้ไม่ถูกเป็นจำนวนมาก นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจว่าการกระทำของนายเหี่ยวเป็นการกลับใจไม่กระทำความผิด จึงตอบว่านายเหี่ยวไม่ต้องรับโทษจากการลัทธิพจน์ของนายเฉาเนื่องจากได้นำกระเป๋าสตางค์ไปวางไว้ที่เดิมแล้ว นายเหี่ยวได้รับประโยชน์ตามมาตรา 82 คือไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานลัทธิพจน์ แม้ว่านักศึกษาบางคนสามารถอธิบายหลักเกณฑ์ของมาตรา 82 ได้อย่างถูกต้อง แต่กลับวินิจฉัยว่าการที่นายเหี่ยวนำเอากระเป๋าสตางค์ของนายเฉาไปวางคืนไว้ที่เดิมภายหลังจากการกระทำความผิดไปแล้วนั้นเป็นการกลับใจเข้าแก้ไขการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง และสรุปว่านายเหี่ยวไม่ต้องรับโทษ เช่นนี้นักศึกษาก็จะได้รับคะแนนเฉพาะในส่วนของหลักกฎหมายเท่านั้น ส่วนการวินิจฉัยและสรุปก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้คะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

คำถามข้อนี้มีประเด็นที่นักศึกษาควรจะต้องพิจารณา คือ การกระทำของนายเหี่ยวสำเร็จผลตามเจตนาแล้วหรือไม่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าการกระทำของนายเหี่ยวนั้นครบองค์ประกอบของความผิดฐานลัทธิพจน์ตามมาตรา 334 ประมวลกฎหมายอาญาแล้ว กล่าวคือการกระทำที่ได้เอาทรัพย์สินของผู้อื่นเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมและมีเจตนาที่จะกระทำโดยทุจริต ดังนั้น การกระทำความผิดของนายเหี่ยวจึงสำเร็จผลตามเจตนาแล้ว แม้ภายหลังจะกลับใจเนื่องจากทราบว่ากระเป๋าสตางค์ที่ตนลักมานั้นเป็นของนายเฉาเพื่อนสมัยเรียนแล้วนำกระเป๋าสตางค์ไปวางคืนไว้ที่เดิม แต่นายเหี่ยวก็ไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรา 82 เพราะกรณีที่กระทำความผิดสำเร็จผลตามเจตนาของผู้กระทำ ย่อมไม่มีกรณีการยับยั้งหรือกลับใจเข้าแก้ไขได้อีกต่อไป ผู้กระทำจึงต้องรับโทษจากการกระทำความผิดนั้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัยในครั้งนี้ นักศึกษาคงจะได้รับความกระจ่างและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงการตอบข้อสอบอัตนัยของท่านต่อไป



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายดำต้องการเอามะพร้าวของนายขาวไปขาย นายดำขึ้นไปบนต้นมะพร้าวของนายขาว พ้นมะพร้าวได้หนึ่งทะลายขาดจากต้น แล้วพลาดไถ้บนทางมะพร้าวเพื่อจะตัดทะลายอื่นต่อไป ขณะนายดำกำลังตัดทะลายที่สอง นายขาวมาพบเข้า นายดำจึงลงจากต้นมะพร้าว แล้ววิ่งหนีไปโดยไม่ได้เอามะพร้าวไปด้วย

ดังนี้ นายดำต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 334) บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายดำต้องการเอามะพร้าวของนายขาวไปขาย จึงขึ้นไปบนต้นมะพร้าวของนายขาว และพ้นมะพร้าวได้หนึ่งทะลายขาดจากต้น แล้วพลาดไถ้บนทางมะพร้าวเพื่อจะตัดทะลายอื่นต่อไป จะเห็นว่าการกระทำของนายดำดังกล่าวเป็นการที่นายดำเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้อื่นในลักษณะแย่งการครอบครองแล้ว และเป็นการเอาไปโดยแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยทุจริต แม้นต่อนายขาวได้มาพบเข้า นายดำจึงลงจากต้นมะพร้าวแล้ววิ่งหนีไปโดยไม่ได้เอามะพร้าวไปด้วย แต่การกระทำของนายดำก็เป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่นายดำตัดมะพร้าวขาดจากต้นและพลาดไถ้บนทางมะพร้าวแล้ว

ดังนั้น นายดำจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์ ตามหลักกฎหมายข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ไม่ยาก นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูกประเด็นว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ แต่ที่มีปัญหาก็คือนักศึกษาบางคนไปตอบว่าเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ โดยดูจากโจทย์ว่า นายดำวิ่งหนีไปโดยไม่ได้เอามะพร้าวไปขาย จึงมองว่าไม่เป็นความผิดสำเร็จ

นักศึกษาต้องรู้เสียก่อนว่าความผิดฐานลักทรัพย์คือการที่บุคคลเอาทรัพย์สินไปจากการครอบครองของผู้อื่นในลักษณะแย่งการครอบครอง กล่าวคือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินเขาต้องไม่ยินยอมให้เอาไป ความผิดฐานลักทรัพย์จะเป็นความผิดสำเร็จก็ต่อเมื่อทรัพย์สินที่แย่งไปนั้นต้องได้เคลื่อนที่ไปจากที่เดิมและผู้เอาไปต้องมีอำนาจเหนือทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งจะเอาทรัพย์สินนั้นไปได้ โดยไม่ต้องทำอะไรอีก แต่ถ้าทรัพย์สินเคลื่อนที่ แต่ผู้เอาไปยังไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริง ยังต้องทำอะไรอีกจึงจะเอาทรัพย์สินนั้นไปได้ก็เป็นเพียงพยายามลักทรัพย์

เช่น จำเลยขึ้นไปบนยอดมะพร้าวโดยทุจริตคิดจะลักมะพร้าวของเขา จำเลยได้ฟันมะพร้าวหล่นลงที่พื้น 15 ผล พอดี เจ้าทรัพย์เห็นเข้าจำเลยจึงวิ่งหนีไปเอามะพร้าวไปไม่ได้ กรณีนี้จำเลยผิดแค่พยายามลักทรัพย์ เพราะแม้ทรัพย์คือมะพร้าวจะเคลื่อนที่แล้วก็ตาม แต่จำเลยยังไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์อย่างแท้จริง การที่จำเลยจะเอามะพร้าวไปได้จำเลยต้องมาเก็บลูกมะพร้าวที่หล่นอยู่เสียก่อน หรือจำเลยมีเจตนาลักสร้อยคอเขา จำเลยใช้กรรไกรตัดสร้อยนั้นขาดตกลงยังพื้นดิน มีคนเห็นบอกให้ผู้เสียหายรู้ตัวเก็บสร้อยเสียก่อน จำเลยจึงเอาไปไม่ได้ กรณีที่จำเลยก็ผิดเพียงพยายามลักทรัพย์ เพราะแม้ทรัพย์คือสร้อยคอจะเคลื่อนที่แล้วก็ตาม แต่จำเลยยังไม่มีอำนาจเหนือทรัพย์อย่างแท้จริง การที่จำเลยจะเอาสร้อยไปได้ จำเลยต้องมาเก็บสร้อยที่ตกอยู่ที่พื้นเสียก่อน

กรณีตามปัญหาจะเห็นได้ว่า นายดำได้ฟันมะพร้าวได้หนึ่งทะลายขาดจากต้น แล้วพาดไว้บนทางมะพร้าว ถือว่ามะพร้าวนั้นได้เคลื่อนที่ขาดจากต้น และนายดำมีอำนาจเหนือทรัพย์อย่างแท้จริงพร้อมที่จะเอาไปได้โดยไม่ต้องลงมาเก็บลูกมะพร้าวอีก การกระทำของนายดำจึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว แม้นายดำจะไม่ได้เอามะพร้าวไปด้วยก็ตาม เพราะความผิดสำเร็จตั้งแต่ทรัพย์เคลื่อนที่และนายดำมีอำนาจเหนือทรัพย์แล้ว

นอกจากนี้ นักศึกษายังเสียคะแนนในข้อนี้อีก เช่น ตัวบทขาดคำว่า “โดยทุจริต” ตอนวินิจฉัยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการเอาไปโดยทุจริต หรือบางคนเขียนตัวบทใหม่ เช่น เขียนว่าผู้ใดลักทรัพย์เป็นความผิด ฯลฯ ทั้งหลายเหล่านี้ทำให้นักศึกษาเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนให้มาก พยายามท่องตัวบทให้จำได้ เพื่อที่นักศึกษาจะได้เขียนหลักกฎหมายได้อย่างแม่นยำ ไม่เขียนตัวบทใหม่มาให้อาจารย์อ่านอีก ขอให้โชคดีคะ



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

อาจารย์จตุรนต์ บุญยธนะ

คำถาม

นายไก่อู้เงินนายไข่ 10,000 บาท โดยมีนายขวดเป็นผู้ค้ำประกันในหนีดังกล่าว ภายหลังกายไข่ได้ปลดหนี้ให้แก่นายไก่อ 5,000 บาท นายไก่อจึงได้มีจดหมายบอกกล่าวไปให้นายขวดทราบ แต่นายขวดทำจดหมายของนายไก่อหายเสียโดยยังไม่ทันได้เปิดอ่านข้อความในจดหมายนั้น เมื่อนายไข่มาเรียกร้องให้นายขวดชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน นายขวดจึงได้ชำระหนี้ให้แก่นายไข่เต็มจำนวน 10,000 บาท แล้วจึงมาฟ้องไล่เบี้ยเอาเงินจำนวน 10,000 บาท จากนายไก่อ นายไก่อปฏิเสธไม่ชำระเงินให้นายขวดเต็มจำนวนโดยอ้างว่านายไข่ได้ปลดหนี้ให้ตนและได้มีจดหมายแจ้งให้นายขวดทราบแล้ว

เช่นนี้ให้วินิจฉัยว่าข้ออ้างของนายไก่อฟังขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 695 บัญญัติว่า “ผู้ค้ำประกันซึ่งละเลยไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้นั้นท่านว่ายอมสละสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้เพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้ว่ามีข้อต่อสู้เช่นนั้น และที่ไม่รู้นั้นมิได้เป็นเพราะความผิดของตนด้วย”

วินิจฉัยตามปัญหา

นายไข่เจ้าหนีดตกลงปลดหนี้ให้แก่นายไก่อลูกหนี้จำนวน 5,000 บาท ภายหลังกายไก่อได้มีจดหมายบอกกล่าวให้นายขวดผู้ค้ำประกันทราบแล้ว แต่นายขวดทำจดหมายของนายไก่อหายเสียโดยยังไม่ทันได้เปิดอ่านข้อความในจดหมายและได้ชำระหนี้ให้นายไข่เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเต็มจำนวน 10,000 บาท เช่นนี้ถือว่าการที่ไม่รู้ถึงการปลดหนี้ของนายไข่เจ้าหนี้จำนวน 5,000 บาทแล้วจึงได้ชำระหนี้เต็มจำนวนไปนั้น เป็นเพราะความผิดของนายขวดผู้ค้ำประกันนั่นเอง และกรณีนี้ตาม ปพพ. มาตรา 695 ถือว่านายขวดผู้ค้ำประกัน “ละเลย” ไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้ เนื่องจากคำว่า “ละเลย” หมายถึง รู้แล้วยังไม่ยกข้อต่อสู้อีกโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ดังนั้นนายขวดผู้ค้ำประกันยอมสละสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ลูกหนี้เพียงเท่าที่ไม่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ นั่น คือ สิ้นสิทธิไล่เบี้ยเพียง 5,000 บาท แต่นายขวดยังมีสิทธิไล่เบี้ยนายไก่อลูกหนี้จำนวน 5,000 บาทได้ ข้ออ้างของนายไก่อจึงฟังไม่ขึ้น

สรุป

ข้ออ้างของนายไก่อึ้งไม่ขึ้น เนื่องจากนายชวดสันสิทธิไล่เบี้ยเพียง 5,000 บาท นายไก่อึ้งยังคงต้องชำระหนี้ให้แก่นายชวดจำนวน 5,000 บาท ตาม ปพพ. มาตรา 695 (เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์ 3 หน้า 2-34)

วิเคราะห์

นักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจหลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิไล่เบี้ยดีแล้วตาม ปพพ. มาตรา 693 กล่าวคือ เมื่อผู้ค้าประกันชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาจากลูกหนี้ เพื่อคืนเงินกับดอกเบี้ยและเพื่อการที่ต้องสูญหายได้ แต่นักศึกษาไม่ได้ศึกษาถึงการสันสิทธิไล่เบี้ยตาม ปพพ. มาตรา 695 ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงตามโจทย์เป็นการที่ “นายไก่อึ้งได้มีจดหมายบอกกล่าวให้แก่นายชวดผู้ค้าประกันทราบแล้ว แต่นายชวดทำจดหมายของนายไก่อึ้งหายเสียโดยยังไม่ทันได้เปิดอ่านข้อความในจดหมาย และได้ชำระหนี้ให้นายไก่อึ้งเจ้าหนี้ตามสัญญาการค้าประกัน” นักศึกษาจำนวนหนึ่งจึงอ้างเพียง ปพพ. มาตรา 693 และนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งอ้างถึงหลักกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง คลุมเคลือและไม่ชัดเจน ทำให้เสียคะแนน นอกจากนี้นักศึกษาละเลยไม่วิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ของผู้ค้าประกันตามโจทย์ว่า ผู้ค้าประกันประมาทหรือไม่ รวมทั้งการที่ผู้ค้าประกันประมาทนั้นถือเป็นลักษณะหนึ่งของการ “ละเลย” ไม่ยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้ขึ้นต่อสู้เจ้าหนี้และสันสิทธิไล่เบี้ยหรือไม่ จึงไม่สามารถใช้เหตุผลทางกฎหมายประกอบการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

นายกอบศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทสินทวี จำกัด โดยบริษัทประกอบกิจการขายโทรศัพท์มือถือตามห้างต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท กิจการของบริษัทดำเนินมาด้วยดีตลอดระยะเวลา 5 ปี นางกุหลาบเห็นว่าบริษัทที่นายกอบศักดิ์เป็นกรรมการดำเนินกิจการดีเพราะนายกอบศักดิ์ จึงชักชวนนายกอบศักดิ์ให้มาร่วมลงทุนประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือร่วมกับตนที่จังหวัดเชียงใหม่ นายกอบศักดิ์ได้ตกลงและร่วมลงทุนกับนางกุหลาบเป็นเงิน 1 ล้านบาท ร่วมกับนางกุหลาบโดยไม่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสินทวี จำกัดแต่อย่างใด

ถามว่า การกระทำของนายกอบศักดิ์ที่ไปร่วมลงทุนกับนางกุหลาบเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ปพพ. มาตรา 1168 วรรค สาม บัญญัติว่า “อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผู้เป็นกรรมการประกอบการค้าใด ๆ อันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับการค้าของบริษัทนั้น ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างค้าขายอื่นซึ่งประกอบกิจการมีสภาพเป็นอย่างเดียวกับและแข่งขันกับกิจการของบริษัทโดยมิได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น”

ตามปัญหา การที่นายกอบศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทได้ไปร่วมหุ้นกับนางกุหลาบเพื่อดำเนินกิจการขายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นกิจการที่มีสภาพเดียวกันกับที่นายกอบศักดิ์เป็นกรรมการ แต่การดำเนินการของนายกอบศักดิ์ ไม่เป็นการขายค้าขายแข่งขันกับบริษัท เพราะได้ค้าขายที่จังหวัดเชียงใหม่

การกระทำของนายกอบศักดิ์ จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย การกระทำของนายกอบศักดิ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย นายกอบศักดิ์ สามารถประกอบกิจการขายโทรศัพท์มือถือร่วมกับนางกุหลาบได้

การวิเคราะห์ นักศึกษาที่ตอบข้อสอบกฎหมายพาณิชย์ 4 จะตอบข้อนี้ไม่ถูกเป็นส่วนใหญ่ คือ มีทั้งยกหลักกฎหมายไม่ถูกต้อง ถ้ายกหลักกฎหมายไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จะได้คะแนน ในข้อนี้ แต่บางกรณียกหลักกฎหมายถูกต้อง ก็จะได้คะแนนหลักกฎหมาย แต่พอมาปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายนักศึกษาจะพิจารณาในประเด็นว่าเป็นกิจการที่มีสภาพเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงว่าแม้จะประกอบกิจการสภาพเดียวกันก็ตามแต่การดำเนินการของนายกอบศักดิ์ไม่เป็นการขายค้าขายแข่งขันกับบริษัท เพราะได้ค้าขายที่จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาจึงได้เฉพาะคะแนนหลักกฎหมายแต่ไม่ได้คะแนนปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ธัชพร กังสัช

คำถาม

โจทก์เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อระงับข้อพิพาทในหนี้ค่าจอดเรือ โดยจำเลยเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาจำเลยปฏิบัติผิดสัญญาดังกล่าว

ให้วินิจฉัยว่า โจทก์จะฟ้องจำเลยขอให้บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(1) คำฟ้อง ให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ไม่ว่าจำเลยจะมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่”

วินิจฉัย

การฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งปฏิบัติผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่สร้างขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาทในหนี้ค่าจอดเรื่อนั้นเป็นการฟ้องขอให้บังคับตัวจำเลยจึงเป็นหนี้เหนือบุคคล โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลตาม ป.วิ.พ. มาตรา 4(1) ซึ่งภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งทำการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 68 ส่วนคำว่ามูลคดีเกิดขึ้นหมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องตามสิทธินั้น เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวสร้างขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์จึงเป็นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในเขตศาลไทย โจทก์จึงฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นไม่ได้ แต่จำเลยเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครจำเลยจึงมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครได้

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสนอคำฟ้อง ซึ่งถามว่าโจทก์จะฟ้องจำเลยขอให้บังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครได้หรือไม่ ดังนั้น ในข้อนี้นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. ประเด็นแรกต้องพิจารณาก่อนว่ากรณีดังกล่าวเป็นคำฟ้องประเภทใด นักศึกษาจึงจะสามารถเลือกหลักกฎหมายมาใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งกรณีดังกล่าวการฟ้องขอให้บังคับจำเลยซึ่งปฏิบัติผิดสัญญาประนีประนอมยอมความที่สร้างขึ้นเพื่อระงับข้อพิพาทในหนี้ค่าจอดเรือนั้นเป็นการฟ้องขอให้บังคับตัวจำเลยจึงเป็นหนี้หนี้บุคคล ดังนั้นต้องนำหลักกฎหมายเกี่ยวกับคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้หนี้บุคคลมาใช้ ซึ่งก็คือ มาตรา 4 (1) นั่นเอง ทั้งนี้ ในประเด็นนี้มีนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยผิดว่าเป็นกรณีคำฟ้องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 4 ทวิ ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้หนี้บุคคล

2. ประเด็นต่อมาเมื่อนักศึกษาทราบแล้วว่าเป็นคำฟ้องเกี่ยวกับหนี้หนี้บุคคลและนำมาตรา มาตรา 4 (1) มาบังคับใช้ ซึ่งกำหนดว่า คำฟ้องให้เสนอต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาล ในส่วนนี้นักศึกษาต้องแยกวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน คือ 1) ศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนา และ 2) ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น ในส่วนที่ 1 นักศึกษาต้องทราบว่า จำเลยเป็นบริษัทซึ่งถือเป็นนิติบุคคล ภูมิลำเนาของนิติบุคคลได้แก่ถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือถิ่นอันเป็นที่ตั้งทำการ หรือถิ่นที่ได้เลือกเอาเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการตามข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 68 ดังนั้น กรณีดังกล่าวจำเลยเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนในประเทศไทยและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร จำเลยจึงมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร โจทก์จึงฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครได้

อย่างไรก็ตาม นักศึกษาต้องวิเคราะห์ในส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับ “ศาลที่มูลคดีเกิดขึ้น” นักศึกษาต้องทราบความหมายของมูลคดีเกิดขึ้น ซึ่ง “มูลคดีเกิดขึ้น” หมายถึงต้นเหตุอันเป็นที่มาแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้โจทก์เกิดอำนาจฟ้องตามสิทธินั้น ดังนั้น เมื่อสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวทำขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์จึงเป็นสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในเขตศาลไทย โจทก์จึงฟ้องต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้ ในประเด็น“มูลคดีเกิดขึ้น” นี้ มีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้วินิจฉัยมาเลย ดังนั้น จึงเสียคะแนนในส่วนนี้ไปเป็นจำนวนมาก

คำถาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญากู้เงินโจทก์ไปจำนวน 200,000 บาท ดอกเบี้ยตามกฎหมาย ถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ต่อมาได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้แก่โจทก์โดยยอมรับผิดใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยคืนโจทก์จำนวน 250,000 บาท ครั้นครบกำหนดชำระ จำเลยก็ไม่ชำระแก่โจทก์ ขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ทำไว้แก่โจทก์ จำเลยให้การว่า ความจริงจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้เป็นต้นเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 5,000 บาท ซึ่งจำเลยได้ชำระให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่ได้ทำหลักฐานใดกันไว้ ขอให้ยกฟ้องให้วินิจฉัยว่า จำเลยนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 94 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อใดมีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ห้ามมิให้ศาลยอมรับฟังพยานบุคคลในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ แม้ถึงว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้ยินยอมก็ดี...

(ข) ขอสืบพยานบุคคลประกอบข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อนำเอกสารมาแสดงแล้วว่ามีข้อความเพิ่มเติม ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารนั้นอยู่อีก”

วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้มีใช้ตามสัญญากู้เงินซึ่งไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้ว่า ความจริงจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นต้นเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 5,000 บาท อันเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตามหนังสือรับสภาพหนี้ได้ ไม่ต้องห้ามตามป.วิ.พ.มาตรา 94(ข)

การชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง หรือต้องทำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งกันไว้จึงจะรับฟังได้ จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การว่าชำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์เสร็จสิ้นแล้วได้ไม่ขัดต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสาร ซึ่งถามว่าจำเลยนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้หรือไม่ ดังนั้น ในข้อนี้ นักศึกษามีประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

1. ประเด็นแรกนักศึกษาต้องทราบว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสาร อยู่ในป.วิ.พ. มาตรา 94 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง นอกจากนั้น นักศึกษายังต้องทราบอีกว่า หนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 94 จำเลยจึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้ว่า ความจริงจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นต้นเงิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 5,000 บาท อันเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความตามหนังสือรับสภาพหนี้ได้ ไม่ต้องห้ามตามป.วิ.พ.มาตรา 94(ข) ทั้งนี้ ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าหนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงวินิจฉัยว่า ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสาร ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด

2. ประเด็นต่อมานักศึกษาต้องทราบว่า การชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 94 จึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบตามคำให้การได้ ทั้งนี้ ในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า การชำระต้นเงินและดอกเบี้ยตามหนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงวินิจฉัยว่า ห้ามนำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสาร ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิด



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธวัฒน์ เนติโพธิ์

ในการสอบไล่ภาค 2/2558 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 นี้ นักศึกษาจะเห็นว่าข้อสอบอัตนัยของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 นั้น มีข้อสอบอัตนัย 3 ข้อโดยมีเนื้อหาสาระแต่ละข้อดังนี้

- ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4)
- ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5)
- ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12) แต่ไม่เคยออกสอบอัตนัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

จะเห็นว่าแนวข้อสอบทั้ง 3 ข้อ เป็นไปตามแนวทางที่เคยแจ้งไว้ในบทวิจารณ์ข้อสอบไล่ภาค 1/2558 ซึ่งเคยนำลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายนี้แล้ว ฉะนั้นจะได้นำข้อสอบและธงคำตอบของการสอบไล่ภาค 2/2558 มาให้นักศึกษาพิจารณาทบทวนข้อบกพร่องในการทำข้อสอบดังต่อไปนี้

คำถาม

นายโลมาฟ้องนายหมึกเป็นจำเลยในคดีแพ่ง นายหมึกแต่งตั้งให้นายฉลามเป็นทนายเพื่อต่อสู้คดี นายฉลามได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีภายในกำหนดเวลาแล้ว ต่อมาในวันสืบพยานนายโลมาโจทก์และทนายโจทก์มาศาล นายหมึกจำเลยไม่มาศาล นายฉลามทนายจำเลยมาศาลและเข้าห้องพิจารณาจนศาลออกนั่งพิจารณาแล้ว แต่ได้กลับออกไปเสียก่อนที่จะมีการสืบพยาน ดังนี้จะถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาหรือไม่

ธงคำตอบ

มาตรา ๒๐๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๙๘ ทวิ และมาตรา ๑๙๘ ทรี ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยาน และไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ให้ถือว่าคู่ความฝ่ายนั้นขาดนัดพิจารณา

หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา คือ

1. คู่ความไม่มาศาลในวันสืบพยาน และ
2. ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี

คำว่าคู่ความ หมายถึงโจทก์ หรือจำเลย และให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลผู้นั้นตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความด้วย ตามอุทธรณ์แม้จำเลยจะไม่มาศาล แต่เมื่อทนายความมาศาลแล้วแม้จะไม่ยอมดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตาม ต้องถือว่าจำเลยมาศาล ฉะนั้น จึงไม่ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา (เอกสารคำสอนหน้า 4-14 และเอกสารสถิติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง หน้า 18)

คำถาม

นายเหนื่อและนายไต้เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน นายเหนื่อฟ้องขับไล่ นายไต้ซึ่งเข้ามาทำสวนมะนาวให้ออกจากที่ดินของตนซึ่งมีมูลค่า 800,000 บาท และอาจนำออกให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท นายไต้ต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของมารดาไม่ใช่ของนายเหนื่อและมารดายินยอมให้ตนทำกินในที่ดินนี้ ต่อมาศาลพิพากษาให้นายไต้ออกจากที่ดิน ดังนี้ นายไต้จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้เพียงใดหรือไม่

ธงคำตอบ

มาตรา ๒๒๔ ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้คู่ความอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง เว้นแต่ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทำความเห็นแย้งไว้หรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ หรือถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือคำรับรองเช่นว่านี้ต้องได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลภาคผู้มีอำนาจแล้วแต่กรณี

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิได้ให้บังคับในคดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัวและคดีฟ้องขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

จากความในวรรค 2 จะเห็นว่าคดีฟ้องขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ (หรือที่นิยมเรียกว่าคดีไม่มีทุนทรัพย์) เป็นคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง คดีฟ้องขับไล่ปกติเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์จึงจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้เสมอ แต่วรรค 2 วางข้อจำกัดไว้ว่า หากเป็นการฟ้องขับไล่ผู้เช่าหรือผู้อาศัยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จะอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้

อย่างไรก็ดี ในคดีฟ้องขับไล่ ถ้าจำเลยสู้กรรมสิทธิ์ว่าเป็นของจำเลยจะทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีมีข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์เป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามมาตรา 224 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะต้องห้ามอุทธรณ์หรือไม่ต้องพิจารณาทุนทรัพย์เป็นหลัก แต่คดีที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ในเรื่องกรรมสิทธิ์ก็ดี หรือให้การต่อสู้อ้างว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น มิได้ให้การต่อสู้ว่าเป็นของจำเลยเองก็ดี ไม่ถือว่าจำเลยให้การต่อสู้ในเรื่องกรรมสิทธิ์ ถือว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ แต่จะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาตามมาตรา 224 วรรคสอง (จากเอกสารการสอนหน้า 5-26 และเอกสารสถิติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง หน้า 14)

ตามอุทธรณ์นายไต้ต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของมารดาซึ่งเป็นคนภายนอก ไม่ถือว่าจำเลยต่อสู้ในเรื่องกรรมสิทธิ์อันจะทำให้กลายเป็นคดีมีทุนทรัพย์ คดีฟ้องขับไล่นี้จึงเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้อยู่ต่อไปดังเดิม จึงอยู่ภายใต้วรรค 2 เมื่อปรากฏว่าที่ดินพิพาทอาจนำออกให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท ฉะนั้น แม้เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์แต่นายไต้ก็ไม่สามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้

คำถาม

ในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง นายแกงไก่ถูกหนี้ที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วได้ยื่นคำขอประนอมหนี้ กับที่ประชุมเจ้าหนี้ โดยเสนอว่าจะชำระให้ร้อยละ 70 ของหนี้ทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน 4,000,000 บาท แบ่งชำระเป็น 4 งวด ๆ ละ 1,000,000 บาทโดยนายแกงไก่ได้เสนอให้นายไข่ต้มเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ที่ขอประนอมหนี้ด้วย ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับคำขอประนอมหนี้ของนายแกงไก่โดยให้นายไข่ต้มเป็นผู้ค้ำประกัน และศาลมีคำสั่ง เห็นชอบด้วยการประนอมหนี้แล้ว ปรากฏว่านายแกงไก่ชำระหนี้ตามข้อตกลงประนอมหนี้ได้เพียงงวดเดียว คิดเป็นเงิน 1,000,000 บาทเท่านั้นแล้วไม่ชำระอีก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานต่อศาล และศาลมีคำสั่งยกเลิก การประนอมหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าหนี้ดังกล่าวมีนายไข่ต้มเป็นผู้ค้ำประกัน จึงเรียกให้นายไข่ต้มชำระ หนี้ที่เหลืออีก 3,000,000 บาท จะได้หรือไม่ เพียงใด

ธงคำตอบ

ผู้ค้ำประกันจะรับผิดชอบเมื่อยังมีหนี้ที่ตนประกันผูกพันอยู่ แต่เมื่อศาลมีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ ก็มีผลทำให้ข้อตกลงชำระหนี้ตามขอประนอมหนี้เป็นอันระงับไป ทำให้ผู้ค้ำประกันการประนอมหนี้หลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบไปด้วย (จากเอกสารการสอนหน้า 11-39, คำพิพากษาฎีกาที่ 1157/2510) ฉะนั้น จะเรียกให้นายไข่ต้ม ชำระหนี้ที่เหลืออีก 3,000,000 บาทไม่ได้

ข้อนี้มีเนื้อหาค่อนข้างยาก เพราะนักศึกษาจะสับสนกับผู้ค้ำประกันหนี้ที่มีมาก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ กับผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามคำขอประนอมหนี้ซึ่งเกิดภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ แต่หากนักศึกษาดูตาม อ่านบทวิจารณ์ข้อสอบไล่ภาค 1/2558 ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายนี้แล้วจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้เคยกล่าวเตือน ให้ระวังความคล้ายกันของผู้ค้ำประกันทั้งสองแบบไว้ดังนี้

“ต้องระวังความคล้ายกันของกฎหมายแต่ละเรื่องที่มีผลแตกต่างกันด้วย เช่นเรื่อง การประนอมหนี้ไม่ทำให้ ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากหนี้สิน (ดูมาตรา 59) ฉะนั้น แม้ประนอมหนี้แล้ว เจ้าหนี้ก็ยังมาฟ้องเรียกผู้ค้ำประกันเป็นคดี แ่่งได้อยู่เสมอ และแม้ภายหลังศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ทำให้ลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคล ล้มละลาย ผู้ค้ำประกันก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด (ดูเอกสารการสอนหน้า 11-37) แต่ผู้ค้ำประกันที่กล่าวนี้ คือ ผู้ค้ำประกันหนี้สินของลูกหนี้ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนฟ้องคดีล้มละลายเท่านั้น

ยังมีผู้ค้ำประกันอีกแบบหนึ่ง คือผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ตามคำขอประนอมหนี้ ในกรณีนี้จะมีผลแตกต่าง กับผู้ค้ำประกันหนี้สินที่กล่าวแล้วอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้ค้ำประกันอย่างหลังนี้ได้เป็นผู้ค้ำประกันให้ลูกหนี้มาตั้งแต่ก่อน ฟ้องล้มละลาย แต่เข้ามาทำสัญญาผูกพันตนจะชำระหนี้แทนลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ในคำขอ ประนอมหนี้เท่านั้น ซึ่งต่อมากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามคำขอประนอมหนี้ทำให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้และ มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลายตามมาตรา 60 แล้ว ในส่วนของผู้ค้ำประกันคนหลังนี้จะเห็นว่าเมื่อศาลยกเลิก การประนอมหนี้ ทำให้หนี้ตามที่กำหนดไว้ในคำขอประนอมหนี้เป็นอันยกเลิกไปแล้วกลับไปบังคับกันตามหนี้สินเดิม ที่มีอยู่ก่อนการประนอมหนี้ จึงทำให้ไม่มีหนี้ที่ผู้ค้ำประกันจะต้องผูกพันเป็นประกันอีก ผู้ค้ำประกันจึงหลุดพ้น จากความรับผิดตาม ป.พ.พ.มาตรา 698 (ดูเอกสารการสอนหน้า 11-39 ประกอบฎีกาที่ 1157/2510)”

อย่างไรก็ดี แม้ข้อ 3 ซึ่งเป็นคำถามในส่วนของกฎหมายล้มละลายนั่น แม้จะมีขอบเขตเนื้อหากว้างขวาง แต่ส่วนที่จะออกสอบเป็นข้อสอบอัตนัยนั้นจะถามเฉพาะในประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญทั้งสิ้น ซึ่งนักศึกษาจะเห็นได้

จากแผนภูมิแสดงกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนของคดีล้มละลายที่สำคัญ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารผนวกท้ายโสตติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 3 แล้ว และยังมีการขยายความว่าแต่ละขั้นตอนมีบทบาทใดที่สำคัญและนักศึกษาสามารถอ่านโดยละเอียดจากเอกสารสอนหน้าใด

นักศึกษาจะเห็นว่าคำตอบทั้งหมดปรากฏในเอกสารการสอนแล้วทั้งสิ้น และยังปรากฏในเอกสารโสตติทัศน์ประกอบการสอนเสริมแต่ละครั้งอีกด้วย จึงอยากย้าให้นักศึกษามั่นใจว่าหากอ่านเอกสารคำสอนโดยละเอียดแล้วจะไม่พลาดการสอบแน่นอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารโสตติทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการแก้ไขปรับปรุงนั้น มีเอกสารผนวกแนบท้ายโสตติทัศน์ ซึ่งเป็นการคัดย่อจากคำบรรยายในเอกสารมาสอนมารวบรวมให้นักศึกษาได้อ่านโดยย่อเพื่อสะดวกในการศึกษาเข้าใจนั่นเอง และหากประสงค์จะอ่านเพิ่มเติมในรายละเอียดหรือแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาแล้ว แต่ละย่อหน้าของเอกสารผนวกเหล่านั้นยังได้ระบุไว้ชัดเจนว่า นักศึกษาจะดูได้จากเอกสารการสอนหน้าใดอีกด้วย จึงอยากย้าความสำคัญของเอกสารการสอนและเอกสารโสตติทัศน์ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง

ขอให้นักศึกษาอ่านวิจารณ์ข้อสอบนี้ และปรับแก้ไขข้อบกพร่องในการสอบครั้งที่ผ่านมา ขอให้โชคดีในการสอบครั้งต่อไปครับ

อาจารย์ธวัฒน์ เนติโพธิ์

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

พนักงานอัยการฟ้องจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วรรคหนึ่ง และฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 อีกวรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว จึงลงโทษฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็น บทที่มีโทษหนักที่สุด ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลย เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วรรคหนึ่ง และเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 อีกวรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรม

ดังนี้ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ มีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

มาตรา 212 บัญญัติว่า “คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาที่ให้ลงโทษ ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย เว้นแต่โจทก์จะได้อุทธรณ์ในทำนองนั้น”

จากหลักกฎหมายข้างต้น ห้ามศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย ใช้ในกรณีที่จำเลยอุทธรณ์ คำพิพากษาที่ให้ลงโทษในกรณีที่จำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว แม้ศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดหนักกว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ศาลอุทธรณ์ก็จะพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำเลยให้หนักขึ้นไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการเพิ่มเติม โทษจำเลย

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พนักงานอัยการฟ้องจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วรรคหนึ่ง และฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 อีกวรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้น พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว จึงลงโทษฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ต่อมาจำเลยอุทธรณ์ฝ่ายเดียว โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 วรรคหนึ่ง และ เป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 อีกวรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยจึงเป็น ความผิดหลายกรรม แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลย ศาลอุทธรณ์จึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 297 อีกวรรคหนึ่งได้ เพราะเป็นการพิพากษา เพิ่มเติมโทษจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 212

ดังนี้ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 แต่ไม่มีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้ เพราะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยในคดีที่โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ได้หรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยมีเพียงประเด็นเดียว คือ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียว ต่อมาจำเลยอุทธรณ์แต่เพียงฝ่ายเดียว ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกรรม การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษสองกรรมจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยหรือไม่

ประการที่สอง มีนักศึกษาจำนวนมากไปตอบมาตรา 192 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องห้ามศาลพิพากษาเกินคำขอ

ประการที่สาม มีนักศึกษาบางส่วนไปตอบเรื่องคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ มาตรา 193 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งในคำถามก็ไม่ได้ระบุถึงอัตราโทษเอาไว้ นักศึกษาก็ควรคาดหมายได้ว่าข้อสอบไม่ได้มีประเด็นในเรื่องนี้

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมายหรือจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง ห้ามมิให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการปรับใช้กฎหมาย จึงจำเป็นต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท่ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ชัดเงางาม

คำถาม

นางสายชล สัญชาติไทย เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดรักใคร่ชอบพอกับนายจิมมี สัญชาติอเมริกัน และได้อยู่กินฉันสามีภรรยา กัน เกิดบุตร 1 คน ชื่อ เด็กชายทอม เมื่อทอมอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ได้ติดตามมารดา กลับมาอยู่ประเทศไทย เนื่องจากมารดาได้เลิกอยู่กับนายจิมมี

กรณีตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เด็กชายทอม ได้สัญชาติอเมริกันตามหลักดินแดน และกำหนดให้ บุคคลบรรลุนิติภาวะ เมื่ออายุ 18 ปีบริบูรณ์

ต่อมานางสายชลถึงแก่ความตายทิ้งมรดกให้นายทอม เป็นที่ดิน 1 แปลง 50 ไร่ ขณะที่นายทอม อายุ 19 ปี ต้องการขายที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อกลับไปอยู่กับบิดาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดังนี้ เมื่อนายทอมได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการขายที่ดินแปลงดังกล่าว แต่ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ดังนี้

นายทอมไม่สามารถถือครองที่ดินที่ได้รับจากมารดาได้เพราะมิได้มีสัญชาติไทย และเห็นว่านายทอม มีสัญชาติตามบิดา และตามหลักดินแดนถือสัญชาติอเมริกัน

ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (ตอบโดยยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาประกอบ)

แนวตอบ

พระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา 7 บัญญัติว่า “บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

- (1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย
- (2) ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ยกเว้นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคหนึ่ง”

อธิบาย

นางสายชล สัญชาติไทย กินอยู่ฉันสามีภรรยากับนายจิมมี โดยมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย สหรัฐอเมริกาและกฎหมายไทย และมีบุตร 1 คน คือ นายทอม ซึ่งได้รับรับมรดกจากมารดาเป็นที่ดิน 1 แปลง 50 ไร่ ขณะที่ตนมีอายุได้ 19 ปี และประสงค์จะขายที่ดินดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ที่ดินแจ้งว่านายทอมไม่สามารถถือครองที่ดินได้เนื่องจากเห็นว่านายทอมไม่มีสัญชาติไทย เพราะมีสัญชาติอเมริกันโดยการเกิดและโดยหลักสายเลือดที่มีบิดา เป็นคนอเมริกัน ปัญหาจึงมีอยู่ว่านายทอมจะได้สัญชาติไทยตามมารดาด้วยหรือไม่

ตามมาตรา 7 (1) ของพระราชบัญญัติสัญชาติของไทย กำหนดให้บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

ดังนั้น การที่นายทอมแม้ว่าจะเกิดในสหรัฐอเมริกา (นอกราชอาณาจักรไทย) ก็ย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดาด้วย ซึ่งกฎหมายก็มีได้บังคับไว้ด้วยว่ามารดาต้องมีการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายกับบิดา ดังนั้น แม้จะเป็นเพียงการอยู่กินฉันสามีภรรยา (เป็นบุตรนอกสมรส) ก็เป็นการเพียงพอที่ทำให้นายทอมได้สัญชาติไทยตามมารดาแล้ว

สรุป

ดังนั้น ข้ออ้างของเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่านายทอมถือครองที่ดินไม่ได้เพราะไม่มีสัญชาติไทยนั้นจึงฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

นักศึกษาส่วนหนึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตอบ ซึ่งมีใช้วัตถุประสงค์ของคำถามที่ประสงค์จะให้ให้นักศึกษาตอบเช่นนั้น เพราะเป็นข้อสอบชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เรื่องที่เกี่ยวข้องควรต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในเนื้อหาของชุดวิชานี้ คือเรื่องของกฎหมายสัญชาติ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 และโจทย์ข้อนี้ไม่มุ่งประเด็นให้ตอบข้อพิพาทว่าด้วยการจัดกันแห่งกฎหมาย แต่มุ่งประเด็นข้อถามกรณีการได้สัญชาติของบุตรซึ่งเกิดจากหญิงไทยที่ไม่ได้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย จะได้สัญชาติตามมารดาด้วยหรือไม่ โจทย์ไม่ได้ถามถึงกรณีของบิดาซึ่งเป็นคนสัญชาติอเมริกัน จึงไม่ต้องนำมาวินิจฉัย และเมื่อบุตรสามารถได้สัญชาติไทยตามแม่แล้ว (พระราชบัญญัติสัญชาติ มาตรา 7) และแม้จะได้สัญชาติอื่นด้วยในขณะเดียวกันก็มีใช้ประเด็นที่จะทำให้การได้สัญชาติไทยต้องสูญเสียไปแต่อย่างใด ดังนั้น นายทอมจึงมีสิทธิถือครองที่ดินได้ เพราะมีสัญชาติไทยดังกล่าว



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

นายกกนกทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายอนันต์โอนที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งให้แก่นายอนันต์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย และศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมจนคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมานายกกนกซึ่งมีชื่อในโฉนดที่ดินจดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นให้แก่นางสาวอานโดยนางสาวอานทราบถึงสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว นายอนันต์มาเรียกร้องเอาที่ดินจากนางสาวอานอ้างว่าตนมีสิทธิในที่ดินนั้นส่วนนางสาวอานก็อ้างว่าตนได้รับการโอนทางทะเบียนยอมมีสิทธิดีกว่า

ให้วินิจฉัยว่า นายอนันต์จะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินนั้นได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 1300 บัญญัติว่า “ถ้าได้จดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่บุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนไซ้ ท่านว่าบุคคลนั้นอาจเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ แต่การโอนอันมีค่าตอบแทน ซึ่งผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริตนั้นไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด ท่านว่าจะเรียกให้เพิกถอนทะเบียนไม่ได้”

วินิจฉัย

ตามปัญหานายกกนกทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับนายอนันต์โอนที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งให้แก่นายอนันต์ตามสัญญาจะซื้อจะขาย และศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมจนคดีถึงที่สุดแล้ว เช่นนี้ สิทธิของนายอนันต์ตามคำพิพากษาที่จะเรียกร้องให้นายกกนกปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือไปจดทะเบียนโอนที่ดินนั้นให้แก่ตนย่อมเกิดขึ้นทันที นายอนันต์จึงอยู่ในฐานะที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิของตนตามคำพิพากษาได้อยู่ก่อนแล้ว (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5726/2551) ต่อมานายกกนกซึ่งมีชื่อในโฉนดที่ดินจดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นให้แก่นางสาวอานโดยนางสาวอานทราบถึงสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว จึงเป็นการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทางเสียเปรียบแก่นายอนันต์ซึ่งเป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน แม้การจดทะเบียนโอนที่ดินนั้นให้แก่นางสาวอานจะมีค่าตอบแทน แต่เมื่อนางสาวอานทราบถึงสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ถือไม่ได้ว่านางสาวอานผู้รับโอนกระทำการโดยสุจริต ดังนั้น นายอนันต์ย่อมเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300

สรุป

นายอนันต์เรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนที่ดินนั้นได้

วิเคราะห์

ข้อนี้โจทย์ถามว่า จะเรียกให้เพิกถอนการจดทะเบียนได้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1300 นักศึกษาที่ไขว้เขวยกเฉพาะมาตรา 1299 ทำให้เสียคะแนน เพราะวินิจฉัยไม่ตรงประเด็น

คำถาม

สัมปลูกบ้านและทำกินอยู่ในที่ดินสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ต่อมาแอบได้เข้าไปตั้งแผงลอยขายของในบริเวณที่ดินดังกล่าว สัมจึงขับไล่ให้แอบรื้อถอนแผงลอยออกไป แต่แอบอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณะไม่ใช่ที่ดินส่วนตัวของสัม ใครก็มีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ เช่นนี้ ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของแอบรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1374 บัญญัติว่า “ถ้าผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย์สิน เพราะมีผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องกับมิชอบด้วยกฎหมายไซ้ ท่านว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะให้ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได้ ถ้าเป็นที่น่าวิตกว่าจะยังมีการรบกวนอีก ผู้ครอบครองจะขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้

การฟ้องคดีเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนนั้น ท่านว่าต้องฟ้องภายในปีหนึ่งนับแต่เวลาถูกรบกวน”

ตามปัญหา สัมปลูกบ้านและทำกินอยู่ในที่ดินสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ต่อมาแอบได้เข้าไปตั้งแผงลอยขายของในบริเวณที่ดินดังกล่าว เช่นนี้ แม้การเข้ายึดถือครอบครองที่ดินสาธารณะของสัมจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็มีผลเพียงทำให้สัมผู้ครอบครองไม่อาจยกสิทธิใด ๆ ขึ้นต่อสู้กับรัฐได้เท่านั้น แต่ในระหว่างราษฎรด้วยกัน สัมผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวอยู่ก่อน ย่อมยกขึ้นต่อสู้กับแอบผู้ซึ่งได้เข้าไปตั้งแผงลอยขายของในบริเวณที่ดินดังกล่าวอันเป็นการเข้ามารบกวนการครอบครองได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3973/2548)

ฉะนั้น การที่แอบอ้างว่าที่ดินสาธารณะไม่ใช่ที่ดินส่วนตัวของสัม ใครก็มีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ จึงหารับฟังได้ไม่

วิเคราะห์

กรณีนี้ นักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ตอบคลาดเคลื่อนว่าเป็นการแย่งการครอบครอง การเข้าไปตั้งแผงลอยขายของในที่ครอบครองของผู้อื่น เป็นการเข้าไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ทำให้เขาครอบครองไม่ปกติสุข มิใช่เขาไปยึดถือหวงกันเอามาเป็นของตนเอง จึงเป็นเพียงการรบกวนการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1374 มิใช่การแย่งการครอบครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1375

เฉลยข้อสอบบัณฑิตศึกษา



ระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์

รศ.ดร.สราวุธ ปิตียาศักดิ์

คำถาม

การพัฒนาจรรยาบรรณของการเป็นนักวิจัยที่ดี ควรทำอย่างไร จงอธิบายโดยละเอียด

แนวการตอบ โดยนายสุทธิวัฒน์ มาตรฐาน¹

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายจรรยาบรรณ หมายถึง ประมวล ความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะ ของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น นักวิจัยซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาหนึ่งเช่นเดียวกับ แพทย์ วิศวกร หรือนักกฎหมาย จึงต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัย

เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัยนั้น คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจรรยาบรรณของ นักวิจัยไว้รวม 9 ประการ โดยประการหนึ่ง ได้แก่ นักวิจัยต้องมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและจิตใจ นอกจากนี้ยังได้กำหนดเกี่ยวกับจรรยาวิชาชีพวิจัยและจริยธรรมการวิจัยไว้ดังนี้

จรรยาวิชาชีพวิจัย หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน และความมีจริยธรรมการวิจัย เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของนักวิจัยในสาขาวิชาชีพของตน

จริยธรรมการวิจัย หมายถึง ประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยควรยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีคุณธรรม คือ คุณงามความดี และมีจริยธรรม คือ ความถูกต้องด้วยศีลธรรม

สำหรับคำว่า Plagiarism นั้น คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติให้ความหมายว่า การคัดลอกผลงาน หรือ การแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นว่าเป็นของตน หรือการลอกเลียนวรรณกรรม Plagiarism หมายถึง การนำแนวคิด งานหรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตน โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือให้เกียรติเจ้าของเดิมหรือ ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้ชัดเจน ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน

ส่วนราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของ Plagiarism หมายถึง การโจรกรรมวรรณกรรมหรือการคัดลอก ผลงาน Plagiarism มาจากภาษาละตินว่า Plagiarism หมายถึง ผู้ลักพาตัว

Plagiarism เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง โดยส่วนใหญ่ Plagiarism มักจะเกิดขึ้นใน 2 วงการ ได้แก่ วงการการศึกษา และวงการวรรณกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้น ก่อให้เกิด พฤติกรรมการตัด-แปะ (copy and paste) ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบอยู่เพียงปลายนิ้ว ทำให้เกิดการกระทำ ความผิดกันมากขึ้น โดยในวงการการศึกษานั้น หากนักเรียน นักศึกษา หรืออาจารย์ กระทำการที่มีลักษณะ Plagiarism

¹ ตุลาการศาลปกครองอุดรธานี นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แนวคำตอบนี้เป็นคำตอบ ข้อสอบชุดวิชาการระเบียบวิธีวิจัยและการวิจัยทางนิติศาสตร์ในปีการศึกษา 2556

ดังกล่าว วงการนี้จะมุ่งไปที่ความซื่อสัตย์ผู้ที่กระทำจะถูกกดดันหรือถูกตำหนิ หากเป็นนักเรียน นักศึกษา อาจถูกตัดคะแนนพักการศึกษาหรือให้ปรับตกในวิชานั้น ส่วนอาจารย์ก็อาจจะถูกสอบสวนและได้รับโทษถึงขั้นถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง สำหรับในแวดวงวรรณกรรม จะมุ่งไปที่การตรวจสอบจรรยาบรรณ ซึ่งนักข่าวก็อาจจะกระทำผิด Plagiarism ได้ในการเสนอข่าวความคิดเห็นของบุคคล โดยละเลยไม่บอกถึงแหล่งที่มาของข้อมูล หรือนักเขียนก็อาจมีพฤติการณ์คัดลอกงานเขียนของผู้อื่นทั้งฉบับหรือบางส่วนแล้วนำมาปรุงแต่งและนำออกเผยแพร่โดยละเลยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือให้เกียรติเจ้าของงานเดิมในแวดวงวรรณกรรมจึงถือเป็นการผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจให้อภัยได้ มาตรการการลงโทษก็อาจจะมีตั้งแต่ปรับเปลี่ยนหน้าที่ พักงาน หรือไล่ออกจากงาน แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ยังมีคำที่เกี่ยวข้องอีกคำคือ Self - Plagiarism ซึ่งหมายถึง การนำเอาผลงานเดิมของตนที่ได้มีการเผยแพร่และผู้ผลิตผลงานได้รับประโยชน์ไปแล้ว นำกลับมาเผยแพร่ใหม่ทั้งฉบับหรือบางส่วน หรือนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง โดยไม่ได้ระบุถึงว่าผลงานดังกล่าวได้เคยเผยแพร่แล้วที่ไหน เมื่อใด ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นงานใหม่ กรณีนี้ถือว่าเป็น Plagiarism เช่นเดียวกัน

ดังนั้น จากความหมายที่คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวแล้ว จึงอาจสรุปความหมายของ Plagiarism ได้ว่า หมายถึงการนำเอาความคิด งาน หรือผลงานของผู้อื่น หรือผลงานของตนเองที่เคยเผยแพร่และได้รับประโยชน์ไปแล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะจัดทำด้วยตนเองหรือว่าจ้างให้คนอื่น หรือนำมาสรุปความใหม่ก็ตาม ด้วยการนำไปใช้ประโยชน์เสมือนว่าเป็นผลงานของตนเองหรือเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือให้เกียรติให้เครดิตกับเจ้าของงานเดิม ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นงานของตน ล้วนอยู่ในความหมายของคำว่า Plagiarism ทั้งสิ้น

ตัวอย่างของ Plagiarism ที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบัน ได้แก่

1. การตัด-แปะ (Copy and paste) ผลงานของผู้อื่นที่ปรากฏอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการวิจัยของตนหรือวรรณกรรมของตน โดยไม่ได้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือให้เกียรติเจ้าของงานเดิม
2. การนำผลงานของเจ้าของงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา และไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของผลงานเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของผลงาน)
3. การนำคำพูด คำกล่าว หรือถ้อยแถลงของบุคคลไปใส่ไว้ในผลงานหรือข้อเขียนของตนโดยไม่ได้ใส่เครื่องหมายัญประกาศ “...” ในถ้อยคำดังกล่าวไว้ และไม่ได้อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล มิได้กล่าวถึงบุคคลเจ้าของคำกล่าวนั้น
4. การนำผลงานเดิมของตนเองที่ได้รับการเผยแพร่และได้รับประโยชน์แล้วกลับมาใช้อีกครั้ง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่โดยไม่ได้อ้างอิงถึงการเผยแพร่ครั้งก่อนไว้
5. การนำแผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ภาพถ่าย ภาพวาด ที่ปรากฏในผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ได้อ้างอิงมาจากที่ใด

ฯลฯ

Plagiarism เกิดขึ้นได้อย่างไร Plagiarism อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้

1. ความกดดัน โดยเฉพาะ Career Pressure หมายถึง ความกดดันที่ต้องผลิตผลงาน มิฉะนั้นจะไม่มี ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือความมั่นคงในหน้าที่การงานลดลง

2. รายได้ โดยเฉพาะสังคมที่เน้นส่งเสริมการวิจัยด้วยเม็ดเงินจำนวนมากเป็นเครื่องล่อใจ
 3. ความภาคภูมิใจว่าทำได้ หมายถึง ความบ้าบิ่นหรืออิทธิमानะของนักวิจัยเองที่เชื่อว่าการกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิดและสามารถกระทำได้
 4. ความเชื่อมั่นในตนเองว่าไม่มีใครจับได้
- ฯลฯ

สำหรับความรับผิดชอบ หากผู้กระทำ Plagiarism กระทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของผลงานหรือผู้อื่น อาจต้องรับผิดชอบละเมิดฐานกล่าวหรือโฆษณาเท็จหลายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามมาตรา 423 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือรับผิดชอบฐานหมิ่นประมาทด้วยการใส่ความผู้อื่น ตามมาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาฐานละเมิดจากการกระทำซ้ำหรือเปลี่ยนแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27 นอกจากนี้ยังถือเป็นการประพฤติดจรรยาบรรณ จรรยาวิชาชีพ และจริยธรรมของนักวิจัยหรือของแวดวงวรรณกรรม แล้วแต่กรณีอีกด้วย

ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรดำเนินการดังนี้

1. เสริมสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ จรรยาวิชาชีพ และจริยธรรมของวิชาชีพ ในวิชาชีพต่าง ๆ
2. หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมมือกันสร้างมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิด Plagiarism ด้วยการให้ความรู้ ข้อแนะนำ และแนวทางที่ปฏิบัติที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้บุคคลในวงการวิชาชีพมีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม เคารพในความคิดเห็นและการให้เกียรติเจ้าของผู้ผลิตผลงาน
3. หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการในการลงโทษผู้กระทำ Plagiarism ดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่นในวงการวิชาชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
4. ในการจัดผลงานทางวิชาการหรือการสร้างสรรค์วรรณกรรม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ในการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ ต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน รวมถึงให้เกียรติแก่เจ้าของงานเดิมทุกครั้ง
5. นักวิจัยหรือผู้สร้างผลงานจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการนำผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลิขสิทธิ์ไปใช้ โดยต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของผลงานนั้นก่อน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม
6. การนำผลงานเดิมของตนเองที่เผยแพร่และได้รับประโยชน์ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสรุปเปลี่ยนแปลงใหม่กลับมาใช้อีกครั้ง ต้องระบุถึงแหล่งเผยแพร่ข้อมูลครั้งก่อนไว้ด้วยเสมอ
7. ควรมีการบัญญัติกฎหมายใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ดีอยู่แล้วเพื่อให้ครอบคลุมการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็น Plagiarism
8. ควรอ่านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน แล้วเขียนหรือเรียบเรียงด้วยลีลาโวหารของตนเอง และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้ง



ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง

ดร.อุทัย อาทิวะช

คำถาม

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี คำนวณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๓ บัญญัติว่า “การพิจารณาและสืบพยานในศาล ให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย แต่เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควร เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่ชักช้า ศาลมีอำนาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ ในกรณีตามอนุมาตรา (๓) จำเลยอยู่ในอำนาจศาลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศาลได้ออกหมายจับแล้วแต่ยังจับตัวมาไม่ได้ ท่านเห็นว่า บทบัญญัติในอนุมาตรา (๓) ดังกล่าวนี้อาจมีลักษณะของวิธีพิจารณาความอาญาในระบบไต่สวนซึ่งให้พิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ ในกรณีที่จำเลยหลบหนีหรือไม่ประการใด และสมควรที่จะนำบทบัญญัตินี้ไปใช้ในการพิจารณาและสืบพยานในคดีความผิดฐานอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ จงอธิบาย

แนวการตอบ

อธิบายระบบกล่าวหาและระบบไต่สวนพอสังเขป

ประเทศที่ใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาอย่างเช่นประเทศฝรั่งเศสได้ใช้บังคับการพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย (Trials in absentia) มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ หลักเกณฑ์ของวิธีพิจารณาความอาญาลับหลังจำเลยจะขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดว่าเป็นความผิดอุกฤษฏ์โทษหรือมิชฌิมโทษ

ยกตัวอย่างเช่น กระบวนพิจารณาคดีสำหรับคดีความผิดอุกฤษฏ์โทษซึ่งกระทำผิดโดยศาลลูกขุน (La cour d'assises) นั้น แม้ปัจจุบันจะวางหลักเกณฑ์ให้การพิจารณาคดีต้องกระทำต่อหน้าจำเลย ตามบทบัญญัติของมาตรา ๓๑๗ ถึง ๓๒๐-๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฝรั่งเศส เช่นเดียวกับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศต่าง ๆ ก็ตาม แต่ในกรณีที่จำเลยปฏิเสธไม่มาปรากฏตัวในศาล มาตรา ๓๑๙ ให้อำนาจประธานศาลลูกขุนในการออกหมายเรียกจำเลยมา โดยสามารถขอความช่วยเหลือจากกองกำลังของรัฐในการจัดการดังกล่าวได้ ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก ประธานลูกขุนอาจสั่งให้กองกำลังนำตัวจำเลยมาศาล ในกรณีจำเลยขัดขืน ประธานศาลลูกขุนมีอำนาจสั่งให้ดำเนินการสืบพยานต่อไปลับหลังจำเลยและให้ถือว่าคำพิพากษาในกรณีดังกล่าวมาจากการพิจารณาคดีที่เป็นปฏิปักษ์กัน นอกจากนี้ตามมาตรา ๓๒๐ ในกรณีที่จำเลยไม่มาศาลโดยปราศจากเหตุผลที่ชอบ ตั้งแต่เวลาเริ่มการพิจารณาคดีนัดแรกหรือระหว่างการพิจารณาคดีไม่ว่าในนัดใด ศาลลูกขุนมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลย (défaut criminel) ได้ และไม่มีเหตุผลที่จะรอกการพิจารณาไว้จนกว่าจะได้ตัวจำเลยมาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗๙-๒

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี คำนวณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๓ ซึ่งบัญญัติให้ศาลสามารถพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ ในกรณีที่หลบหนีและศาลได้ออกหมายจับแล้ว แต่ยังไม่จับตัวมาได้นั้น จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของวิธีพิจารณาความอาญาในระบบไต่สวนซึ่งให้พิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ ในกรณีที่จำเลย

หลบหนี ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้คดีขาดอายุความไปก่อนที่จะได้ตัวจำเลยมาพิจารณาคดี และยังช่วยบรรเทาความเสียหายและความทุกข์ทรมานของผู้เสียหายและสังคมที่ได้รับจากการกระทำความผิด ในกรณีที่ทางการไม่สามารถนำตัวจำเลยมาดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลได้ และทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายและสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิด

ส่วนคำถามที่ว่า สมควรที่จะนำบทบัญญัติดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและสืบพยานในคดีความผิดฐานอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและเหตุผลที่นักศึกษายกขึ้นอธิบาย นักศึกษาอาจมีความเห็นว่าสมควรนำมาใช้กับคดีความผิดร้ายแรงที่มีลักษณะเช่นเดียวกับคดีค้ำมนุษย์หรือคดีทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ ซึ่งมีบทบัญญัติทำนองเดียวกัน เช่น คดีฆ่าผู้อื่น คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คดียาเสพติด คดีก่อการร้าย คดีฟอกเงิน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีความเห็นว่าจะไม่สมควรที่จะนำบทบัญญัติดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและสืบพยานในคดีความผิดฐานอื่น ๆ นั้น นักศึกษาจะต้องยกหลักของการพิจารณาที่เป็นธรรม (Fair trial) ซึ่งจำเลยจะต้องได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นระบบ (Right to fair trial) ซึ่งเป็นหลักของคำตอบ ดังนั้น การพิจารณาคดีจะต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย เช่นหลักการทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ ซึ่งเป็นแนวคิดของระบบกล่าวหาและหลักกระบวนการหลักนิติธรรม (Due process of law) หรือหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และนักศึกษาอาจยกความไม่พร้อมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย หรือความเหมาะสมอยู่แล้วของหลักการตามวิธีพิจารณาดังเดิมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๒ ก็ได้

หมายเหตุ ตัวอย่างของกฎหมายฝรั่งเศสตามคำตอบแรกเป็นเพียงตัวอย่าง อาจมีตัวอย่างกฎหมายของประเทศอื่น ๆ หรือตอบในลักษณะที่เป็นคำอธิบายลักษณะของระบบไต่สวนที่อนุญาตให้การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ในกรณีที่จำเลยหลบหนี ถือว่าเป็นกบฏต่อกฎหมาย (Rebel against the law) หรือ กบฏต่อความยุติธรรม (Rebel against justice) ก็ได้



วิชา 40701 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด และหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง

รศ.มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

จงบอกถึงองค์กรปฏิรูปกฎหมายกับการเปรียบเทียบกฎหมาย และลักษณะที่สำคัญของสกุลกฎหมายโรมานอ -เยอรมนิก

แนวการตอบ

องค์การปฏิรูปกฎหมาย คือ องค์กรระหว่างประเทศ(International Organization) ที่มีการดำเนินการเปรียบเทียบกฎหมายในเชิงระหว่างประเทศ เพื่อจัดทำกฎหมายให้เป็นเอกภาพหรือผสมผสานกัน อันมุ่งจะก่อให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อลดปัญหาหรืออุปสรรคในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันเกิดจากความแตกต่างของกฎหมายภายในแต่ละประเทศ

องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำกฎหมายให้เป็นเอกภาพซึ่งมักถูกเรียกว่า องค์การสร้างกฎหมายหรือองค์การปฏิรูปกฎหมาย(Formulating of Law) เป็นศูนย์กลางของการรวมตัวของรัฐต่างๆ และเป็นเวทีที่ประสานความเห็นระหว่างรัฐเหล่านั้นโดยเป็นหน่วยงานที่สร้างกฎหมายที่เป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ในความพยายามที่จะจัดทำกฎหมายให้เป็นเอกภาพ (Unification of Law) โดยองค์การระหว่างประเทศจะได้คิดค้นวิธีการจัดทำกฎหมายให้เป็นเอกภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้บรรดาประเทศหรือรัฐต่าง ๆ ยอมรับและนำไปใช้ โดยอาจแบ่งได้อย่างกว้างเป็นสองวิธี คือ การจัดทำหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นกฎหมาย(Hard Law) หรือการจัดทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันมีผลผูกพันให้สร้างสิ่งที่มีค่าบังคับเป็นกฎหมาย(Legal Binding) และการจัดทำหลักเกณฑ์ที่ไม่มีค่าบังคับเป็นกฎหมาย(not Legally Binding) แต่อาจมีผลเป็นแรงจูงใจให้รัฐต่างๆ รับไปพิจารณาประกอบการจัดทำกฎหมายภายใน เช่น กฎหมายต้นแบบ(Model Laws) ข้อเสนอแนะ(Recommendations) หรือข้อเสนอแนะทางกฎหมาย(Legal Guide)

สกุลกฎหมายโรมานอ-เยอรมานิก เป็นสกุลกฎหมายแรกในโลกที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ คำว่า “โรมานอ” หมายถึงกรุงโรมและ “เยอรมนิก” หมายถึงเยอรมัน

ลักษณะที่สำคัญของสกุลกฎหมายโรมานอ-เยอรมานิก มีดังนี้

1. เป็นสกุลกฎหมายที่มีความเป็นมาจากกฎหมายโรมันโบราณ นับตั้งแต่สร้างกรุงโรม จนถึงปีที่จักรพรรดิจัสติเนียนสิ้นพระชนม์ รวมเวลาประมาณ 13 ศตวรรษ
2. เป็นสกุลกฎหมายที่เก็บเนื้อส่วนใหญ่จากกฎหมายจักรพรรดิจัสติเนียน ชื่อ “Corpus Juris Civilis” ซึ่งจัดทำในศตวรรษที่ 6 ถือเป็นประมวลกฎหมายที่ทันสมัย มีการนำไปใช้เป็นแบบอย่างกว้างขวาง

3. เป็นสกุลกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับกฎหมายเอกชนมาก การพัฒนาเนื้อหาสาระส่วนใหญ่เป็นเรื่องกฎหมายเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์ ต่อมาแม้จะมีการพัฒนากฎหมายมหาชนออกไปมากแต่แนวคิดในทางกฎหมายเอกชนก็ยังแทรกซึมปะปนเข้าไปด้วย ทำให้มีเรียกกฎหมายโรมันว่า ซิวิลลอว์ (Civil Law) ซึ่งเดิมหมายถึงกฎหมายแพ่งแต่ภายหลังมีความหมายว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร ลักษณะนี้เองทำให้สกุลกฎหมายโรมาน-เยอรมนิก แตกต่างจากสกุลกฎหมายอื่น

4. เป็นสกุลกฎหมายที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจัดทำในรูปประมวลกฎหมาย (Condification)

5. เป็นสกุลกฎหมายที่รื้อฟื้นมาศึกษาในอิตาลีและเยอรมนี ในสมัยคริสต์วรรษที่ 11c และ 12

6. เป็นสกุลกฎหมายที่แพร่หลายในภาคพื้นยุโรป ต่อจากนั้นได้กระจายไปทั่วโลก ทั้งใน ปรัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสได้รับเอาแนวคิดในการทำประมวลกฎหมายและเนื้อหาสาระไปจัดทำกฎหมายของตนให้ดีขึ้นและทันสมัยที่สุดเป็นประเทศแรกคือ ประมวลกฎหมายแพ่งของพระเจ้าโนโปเลียน ค.ศ.1904

หลักการใช้และการตีความในระบบคอมมอนลอว์และแนวโน้มการบรรจบกันของระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์

หลักการใช้และการตีความกฎหมายในระบบคอมมอนลอว์ ระบบคอมมอนลอว์จะพิจารณาจากบ่อเกิดของกฎหมายที่สำคัญในระบบคอมมอนลอว์ ที่มีบ่อเกิดจากคำพิพากษาของศาลในคดีก่อน โดยอยู่บนหลักการที่ว่า ข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน ศาลในระบบคอมมอนลอว์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงในข้อพิพาทแล้วหาเหตุผลจากจากข้อเท็จจริงในข้อพิพาทแต่ละเรื่องนำมาสร้างเป็นหลักกฎหมาย หลักกฎหมายที่ศาลในคดีก่อนสร้างขึ้นผูกพันให้ศาลในคดีหลังต้องถือตาม การสร้างหลักกฎหมายจากข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องทำให้คอมมอนลอว์มีลักษณะที่เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก จึงมีความเป็นไปได้ว่าคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานไม่อาจปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีก่อน จะถือตามคำพิพากษาในคดีก่อนก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงเหมือนกันทุกประการเท่านั้น

สำหรับกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นบ่อเกิดของกฎหมายลำดับรองในระบบคอมมอนลอว์ในส่วนของศาลจะตีความกฎหมายลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรไม่ได้ตีความตามความมุ่งหมายของผู้บัญญัติกฎหมาย เว้นแต่จะเข้ากรณีข้อยกเว้นที่ว่าหากตีความตามตัวอักษรแล้วไม่เป็นผลหรือจะเกิดผลอย่างรุนแรง ศาลจะตีความตามความหมายของผู้บัญญัติกฎหมาย หรือเป็นกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นบัญญัติขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของหลักคอมมอนลอว์โดยตรง ปัจจุบันศาลอังกฤษมีแนวโน้มจะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมากขึ้นและเริ่มมีการยอมรับว่าบทบัญญัติของกฎหมายมีฐานะเท่าเทียมกับคำพิพากษามากขึ้นเรื่อย ๆ

แม้ว่าระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์จะมีความแตกต่างกัน แต่ปัจจุบันกฎหมายทั้งสองระบบมีแนวโน้มที่จะมาบรรจบกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษากฎหมายที่มีหลักสูตรหรือการบังคับให้นักศึกษากฎหมายเรียนรู้กฎหมายข้ามระบบหรือแม้แต่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบคอมมอนลอว์ แต่ในปัจจุบันประเทศอังกฤษก็มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยอุปสรรคบางประการของการไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยอุปสรรคบางประการของการไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรและเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดน นักกฎหมายจากระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ได้มีโอกาสมาประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นด้วยเหตุนี้แนวโน้มการบรรจบกันของระบบกฎหมายทั้งสองจึงมีลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตั้งขึ้นของประชาคมยุโรป และต่อมาพัฒนาเป็นสหภาพยุโรป ที่ประกอบด้วยสมาชิกทั้งประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์ ซึ่งมีผลผูกพันทั้งประเทศสมาชิกและคนชาติของประเทศสมาชิกด้วย

การก่อตั้งประชาคมยุโรปนั้นนอกเหนือจากการที่จะต้องมีกฎหมายที่ใช้กับประชาคมแบบลายลักษณ์อักษรแล้ว ประชาคมยุโรปยังมีองค์กรศาลยุติธรรมซึ่งมีผู้พิพากษามาจากประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายทั้งสองระบบ และโดยหลักการแล้วผู้พิพากษาต้องมีอิสระไม่ขึ้นอยู่กับประเทศของตน ในกรณีนี้การพิพากษาคดีของศาลแห่งประชาคมยุโรปที่แม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากระบบซีวิลลอว์ที่ศาลจะไม่ได้ถือตามคำบรรทัดฐานของศาลก็ตามแต่ก็มีความพยายามที่จะประนีประนอมเข้าสู่ระบบคอมมอนลอว์ด้วย และที่สำคัญคำพิพากษาแห่งประชาคมยุโรปนี้จะตัดสินคดีที่อยู่บนรากฐานแห่งความจริง นโยบายของประชาคมเพื่อประโยชน์ของประชาคมอย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นคำพิพากษาที่อยู่เหนือกฎหมายของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ผู้พิพากษาที่มาทำหน้าที่จะต้องไม่ยึดติดอยู่กับระบบกฎหมายของประเทศของตน วิธีการใช้กฎหมายของประชาคมยุโรปจึงเป็นการใช้กฎหมายที่มีลักษณะประนีประนอมเพื่อให้กฎหมายทั้งสองระบบบรรจบกันได้



ชุดวิชาทรัพย์สินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

1. จงอธิบายการครอบครองในประเด็นต่อไปนี้
 - 1.1 ความเป็นมาของการครอบครอง
 - 1.2 ลักษณะของการครอบครอง
 - 1.3 การครอบครองเปรียบเทียบกับสิทธิอื่น ๆ

แนวตอบ

1.1 อธิบายการครอบครอง

ความเป็นมาของการครอบครอง

ในสมัยโรมัน “ครอบครอง” ไม่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายที่รวบรวมโดย Gaius ก่อนมหาจักรพรรดิ Justinian ซึ่งได้แบ่งแยกการประมวลกฎหมายออกเป็น 4 บรรพ กล่าวคือ บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคลและครอบครัว บรรพ 2 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 3 ว่าด้วยมรดก และบรรพ 4 ว่าด้วยวิธีพิจารณาความ แม้แต่ในบรรพ 2 ว่าด้วยทรัพย์สินนั้น ก็ได้บัญญัติเรื่อง “ครอบครอง” ไว้โดยตรง ทั้งในกฎหมายก็ได้รับรองว่า “ครอบครอง” เป็นสิทธิ ซึ่งมีแต่กล่าวถึงอยู่ในบรรพ 4 ว่าด้วยวิธีพิจารณาความ ในเรื่องวิธีฟ้องและดำเนินการพิจารณาเท่านั้นว่า “ถ้าผู้ครอบครองต้องถูกแย่งการครอบครองด้วยกำลังหรือถูกรบกวนในการครอบครอง ผู้ครอบครองนั้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งเรียกว่า Praetor มีคำสั่งให้คืนการครอบครองที่ถูกแย่งการครอบครอง หรือห้ามรบกวนการครอบครองนั้นได้ ซึ่งคำสั่งในกรณีที่มีการแย่งการครอบครองด้วยกำลัง เรียกว่า Interdictum unde vi ส่วนคำสั่งในกรณีรบกวนการครอบครองเรียกว่า Interdictum uti possidetis หรือถ้าผู้ครอบครองต้องถูกแย่งการครอบครองจากผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ยึดถือไว้โดยไม่มีสิทธิอย่างใด Praetor อาจมีคำสั่งให้คืนด้วยคำสั่งที่เรียกว่า Interdictum de precario

ในยุคกลาง แม้ยังไม่มี การรับรองว่า “ครอบครอง” เป็นสิทธิ แต่ก็มีแนวคิดว่า “ครอบครอง” เป็นอุปกรณ์ของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นอำนาจอย่างหนึ่งในกรรมสิทธิ์ (incident of ownership)

ในยุคปัจจุบัน ประมวลกฎหมายของประเทศเยอรมันนี ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ได้บัญญัติแยก “ครอบครอง” ออกเป็นสิทธิต่างหากแล้ว ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยบัญญัติรับรอง “ครอบครอง” ไว้ว่าเป็นสิทธิ ดังปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน

1.2 ลักษณะของการครอบครอง

“ครอบครอง” กับ “สิทธิครอบครอง” นั้น เป็นอันเดียวกันแม้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะใช้ “ครอบครอง” ในมาตรา 1380 หรือจะใช้ “สิทธิครอบครอง” ในมาตรา 1367 ก็ตาม เพียงแต่ว่าเมื่อกล่าวถึง

ในแง่สิทธิก็จะเรียกว่า “สิทธิครอบครอง” ส่วนกิริยาที่ผู้ครอบครองกระทำต่อทรัพย์สินนั้นคือ “ครอบครอง” ทั้งสิทธิครอบครองในทางแพ่งก็ไม่ต่างกับสิทธิครอบครองในทางอาญา

ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของครอบครอง

(1) ครอบครองเป็นสิทธิหรือไม่

Savigny นักกฎหมายคนสำคัญในสมัยโรมัน เห็นว่า ตามกฎหมายโรมันนั้น เรื่องครอบครองเป็นหนี้เกิดแต่การละเมิดครอบครองเท่านั้น

Alciatus, Halm, Gans และ Holland นักกฎหมายคนสำคัญ เห็นว่า “ครอบครอง” ไม่ใช่แต่จะเป็นสิทธิเท่านั้น แต่ยังอยู่ในประเภททรัพย์สิน (jura in re) เสียด้วยซ้ำ

สำหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติบรรพ 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1367 บัญญัติว่า “บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้นได้ซึ่งสิทธิครอบครอง” เห็นได้ชัดว่ากฎหมายบัญญัติให้ “ครอบครอง” เป็นสิทธิ นั่นคือสิทธิครอบครอง (Posses-sory right)

เหตุผลที่ให้การคุ้มครองการครอบครอง คือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคม ป้องกันไม่ให้เอกชนทะเลาะวิวาทกันด้วยการใช้กำลังเข้าแย่งการครอบครองทรัพย์สินซึ่งกันและกัน

(2) ครอบครองเป็นทรัพย์สินหรือไม่

Salmond นักกฎหมายชาวอังกฤษได้กล่าวถึง “ครอบครอง” ไว้อย่างน่าสนใจ “ครอบครอง” เป็นแต่เหตุการณ์ ส่วนกรรมสิทธิ์ที่เป็นสิทธิตามกฎหมาย “ครอบครอง” เป็นการใช้ทรัพย์สินเสมือนดังว่ามีสิทธิ กล่าวคือ กรรมสิทธิ์เป็นการรับรองของกฎหมายให้ใช้สิทธิได้ ทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลโดยความประสงค์ จงใจของรัฐบาลิบัติที่แสดงออกโดยข้อรับรองของกฎหมาย ซึ่งโดยมากแล้วกรรมสิทธิ์กับ “ครอบครอง” จะอยู่ด้วยกัน ส่วนครอบครองจึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงออกภายนอกถึงการมีอยู่ซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย หากกรรมสิทธิ์กับครอบครองมิได้อยู่ด้วยกันเพราะเหตุขัดขวางบางอย่าง เช่น โดยละเมิดแย่งการครอบครอง “ครอบครอง” โดยไม่มีกรรมสิทธิ์ย่อมไม่ได้รับรองเต็มที่ตามกฎหมายกรรมสิทธิ์ปราศจากการครอบครองก็เป็นแต่สิทธิตามกฎหมาย ครอบครองนานอาจเป็นทางให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ปราศจากการครอบครองนาน ๆ ก็อาจสูญสิ้นไปซึ่งกรรมสิทธิ์ได้

หลักที่ใช้กันในกฎหมายของประเทศอังกฤษมีว่า “ครอบครองใด ๆ จะผิดถูกหรือไม่ ก็ยังเป็นการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดการครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” (Any possession is legal possession against wrongdoers) ซึ่งในประเด็นนี้ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เห็นว่า “ครอบครอง” ไม่ต้องอาศัยกรรมสิทธิ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์หรืออำนาจหน่วยหนึ่งของกรรมสิทธิ์และอาจเป็นสิทธิที่ขัดแย้งฝ่าฝืนต่อกรรมสิทธิ์ก็ได้ เช่น ผู้ที่ไปขโมยทรัพย์สินของคนอื่นมาครอบครองย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่ยังได้สิทธิเท่าที่ครอบครองจะให้ได้ และถ้าครอบครองไปนาน ๆ อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่สุด โดยการครอบครองปรปักษ์ หรือกรณีจำนำทรัพย์สินประกันหนี้ ผู้รับจำนำมีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นโดยไม่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ไม่อาจเรียกคืนได้จนกว่าลูกหนี้จะได้ชำระหนี้แล้ว ดังนี้แล้วจะกล่าวว่าครอบครองกับกรรมสิทธิ์เป็นเรื่องเดียวกันเสมอไปย่อมลงไม่ได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยได้แบ่งแยก “ครอบครอง” ไว้ต่างหากโดยลำพัง ไม่รวมไว้ด้วยกับกรรมสิทธิ์

1.3 การครอบครองเปรียบเทียบกับสิทธิ

ประเด็นเปรียบเทียบครอบครองกับสิทธิอื่น ๆ

(1) การเกิดสิทธิ

สิทธิอื่น ๆ โดยทั่วไปจะเกิดแต่การอันชอบด้วยกฎหมาย แต่ “ครอบครอง” อาจเกิดขึ้นได้โดยการอันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงถือกันว่า “ครอบครอง” เป็นสิทธิที่ได้มาตามเหตุการณ์หรือตามข้อเท็จจริง (de facto) ส่วนสิทธิอื่นได้มาตามกฎหมาย (de jure)

ผลของสิทธิ

สิทธิอื่น ๆ โดยทั่วไป กฎหมายจะกำหนดไว้ว่ามีสิทธิอย่างไร เช่น กรรมสิทธิ์ มีกำหนดไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1336 หรือสิทธิอาศัย มีกำหนดไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1402 หรือสิทธิเก็บกิน มีกำหนดไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1417 เป็นต้น ส่วน “ครอบครอง” ไม่ได้มีกฎหมายกำหนดสิทธิต่าง ๆ เช่นนั้นไว้ มีแต่ ป.พ.พ. มาตรา 1372 บัญญัติว่า “สิทธิซึ่งผู้ครอบครองใช้ในทรัพย์สินที่ครอบครองนั้น ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสิทธิซึ่งผู้ครอบครองมีตามกฎหมาย”

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้กล่าวไว้ว่า ครอบครองมีผลในทางรับ ไม่ใช่ในทางรุก เหมือนกับทรัพย์สินอย่างอื่นทั้งหลาย ดังนั้นในระหว่างครอบครอง การใช้สิทธิต่าง ๆ นั้นก็เป็นไปตามแต่ข้อสันนิษฐานของกฎหมาย หาได้มีบทบัญญัติรับรองว่ามีสิทธิใดโดยตรงไม่

(2) การสิ้นสุดแห่งสิทธิ

สิทธิอื่น ๆ โดยทั่วไปเกิดขึ้นโดยกฎหมายบัญญัติรับรอง เมื่อใดกฎหมายไม่รับรองเมื่อนั้น สิทธินั้นก็ย่อมสิ้นไป หรืออาจมีอยู่ตามกำหนดเวลา เช่น สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ อย่างมากมีเพียง 30 ปี หรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธินั้น สำหรับ “ครอบครอง” เกิดขึ้นและมีอยู่โดยเหตุการณ์ที่ยึดถือด้วยเจตนาครอบครอง ตราบใดที่การยึดถือเช่นนั้นยังคงมีอยู่ “ครอบครอง” ย่อมไม่สิ้นสุดลง และไม่มีจำกัดเวลา แต่เมื่อใดเหตุการณ์ดังกล่าวหมดสิ้นไป “ครอบครอง” ก็ย่อมสิ้นสุดลงเมื่อนั้น